

**El déficit de estándares de valoración probatoria en la justicia electoral
mexicana:
protocolo de administración indiciaria y umbral de suficiencia verificables**

Tesis de Maestría
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales · División de Estudios de Posgrado

Índice

Capítulo 1. Categorías de epistemología jurídica para la prueba por indicios.....	1
1.1. La decisión sobre los hechos es una operación de conocimiento sujeta a control racional.....	1
1.1.1. La conquista histórica de la racionalidad probatoria.....	2
1.1.2. Realismo moderado y modelo cognoscitivista.....	3
1.1.3. Los dos proyectos de la epistemología jurídica.....	6
1.2. La averiguación de la verdad es la función epistémica del proceso.....	7
1.2.1. Verdad y justicia de la decisión.....	7
1.2.2. Las concepciones ritual y retórica.....	9
1.2.3. La relatividad de la verdad procesal.....	10
1.3. La actividad probatoria se descompone en tres momentos.....	12
1.3.1. La conformación del conjunto de elementos de juicio.....	12
1.3.2. La valoración.....	14
1.3.3. La decisión y el estándar de prueba.....	15
1.4. La inferencia probatoria tiene una estructura identificable.....	16
1.4.1. Las dos fases y la cadena de inferencias.....	17
1.4.2. Razones, garantía y respaldo.....	18
1.4.3. Las fuentes de la garantía.....	19
1.5. La solidez de la inferencia admite criterios de control.....	21
1.5.1. La vaguedad de la sana crítica.....	21
1.5.2. Criterios sobre los hechos probatorios y sobre la garantía.....	22
1.5.3. Criterios sobre la hipótesis y gradualidad de la solidez.....	25
1.6. El conjunto probatorio excede la suma de sus elementos.....	26
1.6.1. Las objeciones al tratamiento aislado de los elementos de prueba.....	27
1.6.2. Los anclajes del derecho mexicano.....	28
1.6.3. Los riesgos del holismo y el dominio de cada modelo.....	29
1.7. Libre convicción como principio metodológico negativo; la sana crítica no es criterio.....	31
1.7.1. Principio negativo y criterio positivo.....	31
1.7.2. La deriva subjetivista.....	32
1.7.3. La sana crítica y la exigencia de explicitación.....	33
1.8. Un estándar subjetivo no es un estándar.....	34
1.8.1. Los tres atributos de un estándar.....	34
1.8.2. La corrupción de la duda razonable y las dos vías convencionales.....	35

1.8.3. Uniformidad y distribución del error.....	37
1.9. Motivación como control externo de la inferencia.....	38
1.9.1. La garantía de cierre y sus dos funciones.....	38
1.9.2. Motivación-actividad y motivación-documento.....	40
1.9.3. Completitud y contenido exigible.....	42
1.10. Recapitulación: nueve categorías operativas.....	44
1.10.1. Las nueve categorías.....	45
1.10.2. Alcance y límites de la rejilla.....	47

Capítulo 1

Categorías de epistemología jurídica para la prueba por indicios

SUMARIO: 1.1. *La decisión sobre los hechos es una operación de conocimiento sujeta a control racional.* 1.2. *La averiguación de la verdad es la función epistémica del proceso.* 1.3. *La actividad probatoria se descompone en tres momentos.* 1.4. *La inferencia probatoria tiene una estructura identificable.* 1.5. *La solidez de la inferencia admite criterios de control.* 1.6. *El conjunto probatorio excede la suma de sus elementos.* 1.7. *Libre convicción como principio metodológico negativo; la sana crítica no es criterio.* 1.8. *Un estándar subjetivo no es un estándar.* 1.9. *Motivación como control externo de la inferencia.* 1.10. *Recapitulación: nueve categorías operativas.*

1.1. La decisión sobre los hechos es una operación de conocimiento sujeta a control racional

Todo litigio se decide sobre hechos. Antes de aplicar norma alguna, el juzgador debe establecer qué ocurrió, y de esa determinación depende cuanto venga después: la calificación jurídica, la consecuencia prevista y el sentido del fallo. La operación parece sencilla y no lo es. El juez no presenció los acontecimientos sobre los que resuelve y llega a ellos por vía indirecta, a través de documentos, imágenes y declaraciones de fiabilidad desigual, aportados además por quienes tienen interés en el resultado. En materia electoral esa distancia se acentúa. Los hechos que suelen alegarse —la entrega de propaganda, la presión sobre el electorado, la intervención de servidores públicos durante la jornada— ocurren de forma dispersa, en miles de puntos simultáneos, sin registro oficial y ante testigos que rara vez son neutrales.

La tradición jurídica ha dedicado a esa operación mucho menos esfuerzo que a la interpretación de las normas. Sobre cómo debe entenderse un precepto existen escuelas, métodos y una densa jurisprudencia de control. Sobre cómo debe

establecerse un hecho, el derecho ofrece poco más que remisiones genéricas a la lógica, a la sana crítica y a la experiencia, fórmulas que nombran el problema sin resolverlo. La asimetría resulta llamativa si se repara en que el margen de apreciación del juzgador es mayor al fijar los hechos que al interpretar la ley, y en que la mayoría de los litigios se gana o se pierde en el terreno fáctico. Donde más poder se ejerce es donde menos controles se han construido.

De esa desproporción nace una pregunta previa a cualquier método de valoración. La valoración de la prueba admite control racional o queda entregada a la conciencia del juzgador, y entre esas dos posibilidades no existe término medio. La primera alternativa supone que la fijación judicial de los hechos constituye una operación de conocimiento, susceptible de acierto y de error y sujeta por ello a criterios de corrección. La segunda la convierte en un acto de voluntad que se agota en su propia enunciación. Tres razones sostienen la primera. La racionalidad probatoria fue una conquista histórica y no un rasgo definitorio de la función judicial. El conocimiento de hechos admite, además, un realismo moderado que evita por igual la infalibilidad del juzgador y el escepticismo sobre la prueba. Ese realismo se traduce, por último, en un modelo que exige enunciados verdaderos y controlables desde fuera de la sentencia.

1.1.1. La conquista histórica de la racionalidad probatoria

La tradición jurídica trató durante siglos el conocimiento de los hechos como una cuestión pacífica. El lema de esa tradición es exacto: «Los hechos son los hechos y no necesitan ser argumentados». La confianza descansaba en la evidencia de los hechos, y lo evidente no reclama justificación alguna. Esa seguridad, sin embargo, nunca estuvo presente en todos los modelos judiciales. La historia del empirismo es la crónica de los intentos y fracasos por encontrar un lugar para el conocimiento empírico dentro de la racionalidad (Gascón Abellán, 2010, p. 11). La premisa tradicional resulta falsa como descripción histórica, y su falsedad no constituye una curiosidad erudita.

Durante un largo periodo la construcción de la premisa fáctica se apoyó en ritos y procedimientos mágicos donde no cabía apelación alguna a la razón. Esa etapa constituye una experiencia mística de búsqueda de la verdad: a veces se trató de la búsqueda de una decisión aleatoria o de un dictamen sobrenatural, antes que de un método con apariencias de racionalidad. El caso característico es la ordalía, entendida en sentido amplio como duelo judicial, ordalía y juicio de Dios (Gascón

Abellán, 2010, p. 12). Caminar sobre brasas incandescentes sin sufrir lesión resolvía la imputación, y recoger un anillo sumergido en agua hirviendo producía idéntico efecto. Esas prácticas no averiguaban hechos: los sustituían por un veredicto de origen sobrenatural. El vencimiento en duelo demuestra la fuerza, la destreza o la suerte del reo, pero nada acerca de los hechos imputados. Gascón Abellán (2010) concluye que el proceso se convierte entonces en un medio que constituye la verdad, en lugar de un medio que intenta averiguarla (p. 13).

Contra lo que suele suponerse, el tránsito hacia la prueba legal tasada mejoró la apariencia de racionalidad sin alterar la estructura del problema. La prueba de ordalía y la prueba legal constituyen supuestos de prueba formal, porque ambas excluyen la libre valoración del juez. Una y otra la sustituyen por un juicio infalible y superior. La fijación de los hechos en todo sistema tasado adopta un carácter encubiertamente deductivo: si la confesión prueba de manera incontrovertible la culpabilidad y el reo confesó, entonces el reo resulta culpable por necesidad lógica. Ese procedimiento no aspiraba a una verdad probable, sino real (Gascón Abellán, 2010, p. 15). El ritual probatorio valía por sí mismo, con independencia de los hechos que decía acreditar.

De esa reconstrucción se sigue la consecuencia que aquí interesa. La comprensión de la actividad judicial como operación racional constituye una cualidad asociada a determinada cultura jurídica, y no un rasgo conceptual o definitorio de aquella (Gascón Abellán, 2010, p. 13). La racionalidad probatoria se conquistó a lo largo de siglos y, por lo mismo, puede perderse sin que ninguna norma se derogue. Una práctica valorativa puede dejar de aplicarse sin que ningún criterio resulte abandonado de manera expresa, porque lo que la sostiene no es un precepto aislado sino una cultura jurídica que puede desvanecerse.

1.1.2. *Realismo moderado y modelo cognoscitivista*

La distinción entre verdad y prueba organiza el problema epistemológico del proceso. La primera designa la correcta descripción de un mundo independiente, y la segunda, la descripción de ese mundo formulada en el proceso (Gascón Abellán, 2010, p. 40). Dos tradiciones cancelaron esa dualidad por caminos opuestos. La ciencia procesal continental las identificó desde una epistemología realista acrítica. La tradición del *common law* las canceló desde el extremo contrario, al sostener que no hay más verdad que la procesalmente declarada. Ambas desembocan en el mismo corolario inquietante: los jueces serían, por definición, infalibles (p. 40). Ese

corolario resulta inadmisibile para cualquier teoría que aspire a controlar la decisión sobre los hechos, porque un juez infalible es un juez incontrolable.

La distinción entre esos dos conceptos es posible e incluso necesaria si se quiere dar cuenta del carácter autorizado, pero falible, de la declaración de hechos de la sentencia (Gascón Abellán, 2010, p. 41). Que la decisión ponga fin a la controversia no convierte en verdadero el enunciado que la sostiene. Mantener la distinción obliga a reconocer que la sentencia puede equivocarse; cancelarla convierte el error judicial en una categoría conceptualmente imposible. Un sistema que no puede pensar su propio error tampoco puede diseñar garantías contra él, ni admitir que una parte demuestre haberlo padecido, que es precisamente lo que un recurso pretende. La falibilidad de la sentencia no es una concesión al escepticismo: es la condición de que exista algo que revisar.

La salida no consiste en elegir entre realismo ingenuo y escepticismo. Existe una tercera vía que adopta un paradigma epistemológico que toma en serio las tesis postpositivistas sobre la carga teórica de la observación, sin renunciar por ello a un cierto realismo (Gascón Abellán, 2010, p. 42). El juicio de hecho se concibe como una elección entre reconstrucciones posibles de los hechos de la causa. Resulta racional escoger la hipótesis confirmada en un nivel mayor al de la hipótesis contraria; cuando concurren varias hipótesis sobre el mismo hecho, el criterio racional consiste en elegir la que aparece sustentada por un grado de corroboración probatoria relativamente mayor al de todas las demás (Taruffo, 2013, p. 62).

La distinción entre verdad y prueba pone de manifiesto la necesidad de establecer garantías epistemológicas para que la declaración de hechos se aproxime lo más posible a la verdad (Gascón Abellán, 2010, p. 41). Un tribunal que se declara infalible no necesita esas garantías, porque por hipótesis nunca yerra; un tribunal que niega la posibilidad de conocer tampoco las necesita, porque no hay nada que garantizar. Solo el realismo moderado las vuelve exigibles, y ahí reside su rendimiento: no es una posición intermedia adoptada por prudencia, sino la única desde la cual cabe reclamar un control.

Ese realismo se concreta en un modelo determinado de conocimiento judicial de hechos. Gascón Abellán (2010) lo formula en los siguientes términos:

El modelo epistemológico que vamos a adoptar es el cognoscitivista. Entendemos por tal aquel modelo según el cual los procedimientos de fijación de los hechos se dirigen a la formulación de enunciados fácticos que serán verdaderos si los hechos que describen han sucedido y falsos en caso contrario. (p. 49)

El concepto de verdad que el modelo requiere es el semántico de la correspondencia, y su principal criterio de verdad es la contrastación empírica (Gascón Abellán, 2010, p. 49). La fijación de los hechos no puede resultar, por tanto, del puro decisionismo ni del constructivismo. Debe ser el resultado de un juicio descriptivo sobre hechos a los que se atribuye existencia independiente del proceso. El modelo excluye así, desde el principio, la idea de que la verdad se construya en el tribunal. Esa exclusión tiene un precio y una ventaja: el precio consiste en admitir que la sentencia puede errar, y la ventaja, en que ese error se vuelve alegable por las partes y revisable por el órgano superior, lo que sería imposible si la verdad se agotara en lo declarado.

Los dos adjetivos del modelo cargan con exigencias distintas. Que los enunciados sean fácticos significa que describen hechos acaecidos, de donde deriva una exigencia para el derecho sustantivo: la configuración legislativa del supuesto de hecho debe tener un referente empírico claro (Gascón Abellán, 2010, p. 49). Que los enunciados sean verdaderos plantea el problema principal. El juez carece de acceso directo a los hechos y solo conoce enunciados sobre ellos, cuya verdad debe acreditarse. La verdad de tales enunciados se obtiene casi siempre por vía inductiva. La averiguación se desarrolla a través de cauces institucionales que muchas veces estorban ese objetivo. Las tres dificultades se acumulan cuando la prueba es indirecta, y reforzar al máximo las garantías de verdad del proceso supone una exigencia de motivación (Gascón Abellán, 2010, p. 50).

El juzgador electoral no presencié la entrega de propaganda ni la intervención de servidores públicos en la jornada. Lo que tiene ante sí son enunciados sobre esos hechos, contenidos en documentos, imágenes y notas informativas de fiabilidad desigual. Acreditar la verdad de cada uno de esos enunciados, antes de relacionarlos entre sí, resulta condición de que exista material sobre el cual razonar. Un tribunal que no fija el hecho fuente no dispone de premisas, sino de afirmaciones.

Como esquema teórico, el modelo permite describir de manera simplificada realidades que en la práctica son complejas, y como parámetro permite medir esas mismas realidades (Gascón Abellán, 2010, p. 47). Lo buscado es un modelo epistemológico teórico y útil, cuya utilidad consiste en examinar los procedimientos reales y en realizar una crítica epistémica sobre ellos, comparándolos con los principios derivados del modelo y proponiendo la reforma de los aspectos que se separen de él. Describir y proponer son operaciones distintas, y mantenerlas separadas evita que la crítica se confunda con el diagnóstico.

Un modelo de descubrimiento no puede confundirse con el descubrimiento mismo, ni un modelo de justificación con la justificación. Confundirlos supone incurrir en la falacia de tomar el deber ser por el ser (Gascón Abellán, 2010, p. 48). El riesgo consiste en presentar la práctica real «como si» transcurriera conforme al modelo. Cualquier protocolo de valoración corre ese peligro, porque puede degradarse hasta convertirse en una plantilla que legitime formalmente decisiones que no ejecutaron ninguno de sus pasos. La diferencia entre ejecutar un método y nombrarlo exige que cada operación conste de manera verificable en el texto de la sentencia.

1.1.3. Los dos proyectos de la epistemología jurídica

La disciplina que estudia estas cuestiones recibió un nombre y un programa precisos. Un sistema de justicia penal es primordialmente un motor epistémico: un dispositivo para descubrir la verdad a partir de lo que a menudo comienza con una mezcla confusa de pistas e indicios (Laudan, 2013, p. 23). La descripción conviene igualmente a la situación del juzgador electoral que examina un conjunto de pruebas imperfectas, ninguna de ellas concluyente por sí sola. Si el proceso es un motor epistémico, resulta pertinente preguntar si los procedimientos y reglas que lo estructuran conducen genuinamente a la averiguación de la verdad. Esa pregunta define la disciplina y ordena su programa de trabajo, que el autor delimita en dos proyectos:

De modo que la epistemología jurídica, concebida apropiadamente, consta de dos proyectos: a) uno de carácter descriptivo, consistente en determinar cuáles de las reglas vigentes promueven o facilitan la verdad y cuáles la obstaculizan, y b) otro normativo, consistente en proponer cambios en las reglas existentes al efecto de modificar o eliminar aquellas que constituyan impedimentos graves para la búsqueda de la verdad. (Laudan, 2013, p. 23)

La epistemología jurídica apenas existe como área reconocida de reflexión, pese a la aceptación casi universal de que el proceso busca averiguar la verdad (Laudan, 2013, p. 23). El diagnóstico conserva vigencia en el derecho electoral mexicano, donde la discusión sobre la prueba se ha concentrado en la admisibilidad de los medios y en su valor tasado. La pregunta por la aptitud de las reglas para producir decisiones verdaderas ha recibido, en cambio, atención escasa. El desplazamiento pertinente no consiste en discutir qué pruebas pueden ofrecerse ni cómo deben desahogarse, sino qué debe hacer el juzgador con las que ya obran en el expediente. La diferencia de objeto no es menor, porque un diagnóstico situado

en el tratamiento del material probatorio no exige modificar el catálogo legal de medios, que permanece intacto en cuanto se refiere a su ofrecimiento y a su desahogo.

Los dos proyectos admiten una variante importante. El proyecto normativo no consiste necesariamente en proponer cambios a las reglas existentes. Puede consistir en explicitar el contenido de reglas que ya rigen, cuando el diagnóstico no identifica una regla defectuosa sino una regla nunca desarrollada. Esa variante resulta menos ambiciosa pero gana una ventaja decisiva: puede exigirse de inmediato, sin esperar a que ningún órgano legislativo la incorpore al derecho positivo ni a que se abra un ciclo de reforma.

Una precisión final delimita el alcance de las categorías reunidas. Gascón Abellán y Laudan construyen sus modelos con la mirada puesta en el proceso penal, donde rige la presunción de inocencia y existe una asimetría deliberada entre los tipos de error (Laudan, 2013, p. 22). Ese régimen de garantías no se traslada sin más al derecho electoral. Lo que de ambos autores se toma es algo distinto y más básico: la tesis de que la fijación judicial de los hechos constituye una operación de conocimiento y admite criterios de corrección verificables. Esa tesis no depende de la materia en que se aplique.

1.2. La averiguación de la verdad es la función epistémica del proceso

Buena parte de la teoría procesal contemporánea niega que la averiguación de la verdad sea una finalidad del proceso, o la subordina a la resolución del conflicto y a la legitimación social de la decisión. La tesis contraria puede sostenerse con precisión y conviene enunciarla desde ahora: la averiguación de la verdad no es un ideal externo que el proceso persigue cuando puede, sino la condición que permite al derecho funcionar. De ella se siguen dos consecuencias. La prueba es el único instrumento epistémico admisible dentro del proceso. Y la verdad alcanzable resulta relativa a la cantidad y la calidad de las pruebas disponibles, lo que la vuelve graduable y, por tanto, mensurable.

1.2.1. Verdad y justicia de la decisión

Ferrer Beltrán (2007) aborda el problema desde las condiciones de éxito de la institución probatoria. El punto de partida es la función directiva del derecho. El legislador dicta normas para que sus destinatarios realicen o se abstengan de

realizar determinadas conductas, y añade la amenaza de una sanción para quien no cumpla. Los sistemas jurídicos desarrollados prevén, por eso, órganos cuya función principal consiste en determinar la ocurrencia de los hechos a los que el derecho vincula consecuencias y en imponerlas a los sujetos previstos (Ferrer Beltrán, 2007, p. 29). La cadena completa depende de un eslabón fáctico, y si ese eslabón falla, fallan todos los que penden de él, por impecable que sea la técnica jurídica del resto de la resolución.

El autor prueba esa dependencia mediante un experimento mental. Supone que la sanción se atribuya aleatoriamente, de modo que los órganos de adjudicación sorteen cada mes quién debe ser sancionado y cuántas sanciones se impondrán. En ese escenario no existe vinculación alguna entre la conducta de cada miembro de la sociedad y la probabilidad de ser sancionado. Nadie tiene entonces razón para comportarse conforme a las normas jurídicas. El experimento aísla con nitidez lo que aporta la averiguación de la verdad: sin ella, la norma deja de motivar, porque su consecuencia se desprende de algo distinto de la conducta que la norma describe. La conclusión es que la prueba tiene la función de comprobar la producción de los hechos condicionantes a los que el derecho vincula consecuencias jurídicas. El éxito de la institución probatoria se produce cuando las proposiciones sobre los hechos que se declaran probadas son verdaderas (Ferrer Beltrán, 2007, pp. 30-31).

Que la averiguación de la verdad sea el objetivo institucional de la prueba no significa que sea el único objetivo del proceso. La regulación jurídica de la prueba impone, en muchos casos, excepciones a las reglas de la epistemología general, y esas excepciones protegen otros valores que comparten tutela jurídica con la averiguación de la verdad (Ferrer Beltrán, 2007, p. 31). El derecho electoral ofrece ejemplos inmediatos, empezando por los plazos perentorios que la definitividad de las etapas impone. La existencia de esas excepciones no debilita la tesis: la refuerza, porque solo se concibe como excepción aquello que se aparta de una regla vigente.

Taruffo (2013) formula la misma tesis desde el lado de la justicia de la decisión, en términos que no admiten equívoco. Sostiene que en el proceso los hechos determinan la interpretación y la aplicación del derecho, porque la averiguación de la verdad de los hechos es condición necesaria para la justicia de la decisión (p. 13). El argumento es sencillo y difícil de refutar. Ninguna decisión puede considerarse justa si se basa en una averiguación falsa o errónea de los hechos relevantes. La aplicación correcta de la norma presupone que haya ocurrido el hecho que ella misma identifica como condición (Taruffo, 2013, p. 13). El autor lo

resume en una fórmula memorable: ninguna norma se aplica correctamente a hechos falsos o equivocados.

La averiguación de la verdad constituye solo una de las condiciones de justicia de la decisión, que además presupone un proceso desarrollado de manera correcta y legítima y una norma interpretada correctamente. Se trata de una condición de por sí no suficiente, pero necesaria en todo caso. Que los hechos no se establezcan de manera verdadera basta para que la decisión sea injusta, aunque el proceso se haya desarrollado con toda corrección y la norma se haya interpretado con validez (Taruffo, 2013, p. 14). Ninguna de las tres condiciones es suficiente por separado, y las tres resultan necesarias en su conjunto. Quien pasa por alto la distinción entre condición necesaria y condición suficiente puede concluir, erróneamente, que basta con tramitar bien el proceso para decidir con justicia.

Frente a esa concepción se alzan objeciones que el autor identifica y descarta. Menciona las filosofías que niegan la posibilidad de conocer la realidad externa al sujeto, entre ellas el relativismo radical según el cual cada quien tiene su verdad y nadie se equivoca. Menciona también las concepciones que orientan el proceso solo a resolver controversias, de las que se sigue que la averiguación de la verdad no figura entre sus finalidades. A los sostenedores de esas posiciones los denomina *veriphobics*, o enemigos de la verdad, y observa que son muchos y de clases distintas. Su crítica global es que, si a esas concepciones no les interesa el fundamento factual de la decisión judicial, entonces carecen de interés para quien se ocupa de cómo resolver litigios mediante decisiones justas (Taruffo, 2013, p. 16).

1.2.2. *Las concepciones ritual y retórica*

Dos concepciones merecen examen detenido, porque no niegan la verdad de manera frontal sino que la vuelven irrelevante. La primera es la concepción ritualista, que considera el proceso como un rito celebrado con ciertas modalidades, en lugares específicos y con sujetos vestidos de maneras extrañas. Bajo esa mirada, el proceso opera como una representación teatral cuya función consiste en legitimar la decisión ante los ojos del público que presencia el rito. Lo que cuenta no es la calidad ni el contenido de la decisión, sino el procedimiento que concluye con ella. La prueba queda reducida a una parte del rito, y su función se vuelve retóricamente persuasiva hacia el público (Taruffo, 2013, p. 82). Sirve para hacer creer que la decisión final no fue arbitraria, no para establecer que no lo fue.

El procedimiento de creación y asunción de la prueba sirve, bajo esa concepción, para crear una apariencia, de un modo no distinto de lo que sucede en una representación teatral. El fenómeno admite una lectura benévola, porque un teatro judicial que funciona bien produce consenso social sobre la administración de justicia. La objeción es que esa forma de pensar deja fuera el contenido y la calidad de la decisión. El autor lo enuncia con dureza: un rito eficaz puede legitimar cualquier decisión, incluso la condena de un inocente o la absolución de un culpable (Taruffo, 2013, p. 82). Basta con que el rito resulte eficaz para que la decisión sea aceptada, con lo que la aceptación social sustituye a la corrección sin que ninguna de las dos garantice la otra.

La segunda concepción entiende el proceso como una competencia verbal entre narraciones que termina con la victoria del narrador más eficaz. La prueba se convierte allí en un instrumento de persuasión del que los abogados se sirven para convencer al juez o al jurado. Esta concepción tampoco es extraña ni marginal, pues resulta típica de quienes participan en el proceso con el fin de que su cliente venza. La objeción es que también ella deja de lado el contenido y la calidad de la decisión. Ocurre con frecuencia que la victoria corresponde a la parte que desarrolló la mejor narración por ser retóricamente más eficaz, sin que esa narración tenga relación con la realidad de los hechos (Taruffo, 2013, p. 83).

Ninguna de las dos concepciones exige que el juzgador valore el material probatorio, porque en ambas el resultado depende de algo distinto del conocimiento de los hechos. Una sentencia puede, por tanto, cumplir todas las formas del rito — admitir pruebas, celebrar la sesión, publicar la resolución— sin haber ejecutado en ningún momento la operación epistémica que la justifica. La distinción de Taruffo permite nombrar con precisión ese fenómeno: no se trata de una valoración defectuosa, sino de un proceso que operó como rito sin operar como instrumento de conocimiento. La diferencia importa, porque una valoración defectuosa se corrige mejorando el razonamiento y una valoración omitida no se corrige en absoluto.

1.2.3. La relatividad de la verdad procesal

Frente a las concepciones anteriores, Taruffo sitúa la finalidad epistémica en el centro del proceso:

De esta forma se asigna al proceso una finalidad epistémica, ya que el descubrimiento de la verdad de las narraciones factuales se configura como una

condición necesaria de la justicia de la decisión, y entonces también como un objetivo necesario del proceso. (Taruffo, 2013, p. 84)

La verdad así entendida no es absoluta. Taruffo (2013) precisa que en el proceso, como en cualquier experiencia humana incluida la ciencia, no se descubren verdades absolutas, de modo que la verdad procesal debe considerarse relativa (p. 84). Esa relatividad requiere una lectura cuidadosa, y el autor la ofrece. No se trata de verdad relativa en el sentido del relativismo filosófico radical, según el cual cada sujeto tiene su propia verdad. Se trata de que la verdad se fundamenta en informaciones que permiten establecer si un enunciado es cierto, porque se apoya en datos que lo confirman (Taruffo, 2013, p. 84). La formulación decisiva llega enseguida: la verdad de los enunciados sobre los hechos del caso es relativa a la cantidad y la calidad de las pruebas en las que el juez basa su decisión (Taruffo, 2013, p. 84). La verdad opera entonces como un norte, esto es, como un ideal regulativo que orienta la actividad cognoscitiva (Taruffo, 2013, p. 85). Aunque ese norte nunca se alcance, resulta posible establecer cuánto se ha progresado en la dirección que marca.

De esa relatividad deriva una consecuencia con alcance práctico considerable. Si la verdad procesal es relativa a la cantidad y la calidad de las pruebas, entonces el grado alcanzado es susceptible de medición y, por tanto, de enunciación. En el proceso puede establecerse, según las pruebas, en qué grado mayor o menor se ha acercado la decisión a la correspondencia entre los enunciados descriptivos y la realidad que describen (Taruffo, 2013, p. 85). Un estándar de suficiencia probatoria no hace otra cosa que fijar de antemano el grado exigible. La ausencia de estándar no elimina esa graduación, sino que la deja implícita y, con ello, sustraída al control de las partes. El problema no consiste en que los tribunales gradúen, sino en que no digan cómo lo hacen.

La función epistémica de la prueba se articula, además, en dos dimensiones complementarias. La primera es heurística: la prueba sirve para descubrir qué ocurrió, pues antes de su adquisición solo caben ilaciones y narraciones hipotéticas (Taruffo, 2013, p. 85). La segunda es cognoscitiva o demostrativa, porque la prueba aporta los elementos que permiten reconocer el hecho y considerar verificada la verdad de los enunciados que lo describen (Taruffo, 2013, p. 86). De ambas dimensiones deriva una regla exigente. La prueba constituye un instrumento epistémico exclusivo, por ser la única manera posible de adquirir conocimiento de los hechos en el proceso, y resulta además indispensable adquirir todas las pruebas

disponibles (Taruffo, 2013, p. 86). Un tribunal que ignora un elemento que consta en el expediente incumple esa exigencia.

Cuando un hecho no resulta suficientemente probado, el juez no puede pronunciar un *non liquet* y debe decidir de todos modos. Habrá de hacerlo, entonces, aplicando la regla de juicio basada en la carga de la prueba, en lugar del conocimiento de los hechos (Taruffo, 2013, p. 86). Un tribunal que estima insuficiente el material probatorio dispone así de una salida legítima y nombrable, que consiste en declararlo y resolver conforme a esa regla. Lo que no resulta admisible es omitir la valoración y, al mismo tiempo, omitir la invocación de la regla de juicio, porque esa doble omisión deja la decisión sin fundamento epistémico y sin fundamento normativo a la vez.

1.3. La actividad probatoria se descompone en tres momentos

La operación de fijar los hechos no es unitaria y su descomposición en fases tiene rendimiento analítico inmediato. Ferrer Beltrán (2007) propone una descomposición en tres momentos cuya utilidad es doble: permite localizar con precisión en qué fase opera cada restricción jurídica, y permite advertir que la valoración, por sí sola, no decide nada. Entre valorar y resolver media un estándar, y cuando ese estándar no se enuncia el tránsito queda sin control.

1.3.1. La conformación del conjunto de elementos de juicio

Ferrer Beltrán (2007) distingue tres momentos fundamentales: la conformación del conjunto de elementos de juicio sobre cuya base se adoptará la decisión, la valoración de esos elementos y la adopción de la decisión propiamente dicha. Se trata de tres momentos lógicamente distintos y sucesivos, aunque en los procesos reales puedan presentarse entrelazados (p. 41). Esa advertencia importa, porque el entrelazamiento práctico no autoriza a confundirlos en el análisis: cada uno se rige por criterios distintos, y confundirlos produce errores que resultan invisibles mientras la distinción no se traza.

El primero consiste en conformar, mediante la proposición y la práctica de las pruebas, un conjunto de elementos de juicio que apoyen o refuten las distintas hipótesis sobre los hechos del caso (Ferrer Beltrán, 2007, p. 41). En los demás ámbitos del conocimiento el conjunto que puede analizarse coincide con el total de las informaciones disponibles y relevantes. En el derecho, en cambio, el conjunto de

elementos a valorar es un subconjunto del formado por la totalidad de los elementos disponibles: aquellos que han sido incorporados al expediente judicial (p. 42). El juzgador no puede resolver con lo que sabe, sino con lo que consta, y lo que queda fuera del expediente queda fuera del razonamiento por pertinente que sea.

Esa restricción se articula mediante filtros de signo opuesto. El primero es epistemológico y opera como principio general de inclusión: una prueba es relevante si aporta apoyo o refutación de alguna de las hipótesis fácticas del caso a la luz de los principios generales de la lógica y de la ciencia (Ferrer Beltrán, 2007, p. 42). A ese filtro inclusivo el derecho añade reglas de exclusión que se justifican en la protección de valores distintos de la averiguación de la verdad (p. 43). Entre esas reglas figura una que el derecho electoral mexicano aplica con particular rigor: los propios plazos procesales operan como regla de exclusión, de modo que queda fuera toda información aportada fuera de los plazos previstos, aunque sea relevante (p. 43).

La correspondencia con la ley mexicana es exacta. El artículo 15, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establece un catálogo tasado de medios admisibles, que funciona como regla de exclusión de los no enumerados. El artículo 16, párrafo 4, dispone que en ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o aportadas fuera de los plazos legales, salvo la prueba superveniente. Ambos preceptos empobrecen deliberadamente el conjunto de elementos de juicio en nombre de la definitividad de las etapas del proceso electoral. La observación no es una crítica, sino la constatación de que el legislador ya decidió sacrificar riqueza epistémica en el primer momento, lo que vuelve más exigente el tratamiento del material que sí logró entrar.

Ese empobrecimiento tiene una contrapartida institucional. El control de racionalidad puede funcionar a posteriori bajo una condición: debe exigirse al decisor que justifique por qué declaró probados esos hechos y cuál fue el apoyo empírico en el que basó su decisión (Ferrer Beltrán, 2007, p. 44). Los sistemas que carecen de esa exigencia de motivación deben compensarla con reglas de exclusión abundantes, fijadas por anticipado; los que sí la imponen pueden admitir más material y controlar después. El derecho electoral mexicano pertenece al segundo grupo, porque los artículos 14 y 16 de la Constitución imponen fundar y motivar. El control por vía de motivación no es en ese ordenamiento un complemento, sino el mecanismo principal de racionalidad.

1.3.2. *La valoración*

Cerrada la composición del conjunto, comienza el segundo momento. Bajo un régimen de libre valoración, deberá valorarse el apoyo que cada elemento de juicio aporta a las hipótesis en conflicto, de forma individual y en conjunto (Ferrer Beltrán, 2007, p. 45). La fórmula merece subrayarse porque contiene las dos operaciones que el artículo 16, párrafo 3, de la ley mexicana también exige. El resultado buscado consiste en saber el grado de confirmación del que dispone cada una de esas hipótesis. La valoración no produce, por tanto, un veredicto sobre la verdad: produce una magnitud, que es el grado de apoyo conferido a cada hipótesis en competencia. Esa magnitud admite comparación, y confundirla con la conclusión es el primer paso hacia una decisión incontrolable.

El resultado de la valoración es siempre contextual, referido a un determinado conjunto de elementos de juicio (Ferrer Beltrán, 2007, p. 45). Si el conjunto cambia por adición o sustracción de algún elemento, el resultado puede perfectamente ser otro. La consecuencia práctica es de enorme importancia: omitir del conjunto un elemento que consta en el expediente no constituye un descuido menor, porque altera el resultado de toda la operación. Un tribunal que declara inexistente una prueba obrante en autos no comete un error de detalle; valora un conjunto distinto del que tenía ante sí, y obtiene por ello un grado de confirmación que no corresponde al caso que resuelve. El vicio no está en la conclusión, sino en el conjunto sobre el que se razonó.

La libertad que la libre valoración concede existe solo en el sentido de que la valoración no está sujeta a normas jurídicas que predeterminen su resultado. La operación de juzgar el apoyo empírico que un conjunto de elementos aporta a una hipótesis permanece sujeta a los criterios generales de la lógica y de la racionalidad (Ferrer Beltrán, 2007, p. 45). Libertad frente a la prueba tasada no equivale a libertad frente a la razón. Una vez delimitado el conjunto, la operación de valorar lo que de él puede inferirse no difiere de la que se realiza en cualquier otro ámbito de la experiencia (p. 46).

De esa caracterización se sigue una réplica a quien alegue que las restricciones del proceso electoral impiden valorar con rigor. Si en el momento de la valoración no rigen reglas jurídicas que predeterminen el resultado, entonces negar la posibilidad de decidir racionalmente en esa fase no puede fundarse en razones específicamente jurídicas. Ferrer Beltrán (2007) lo expresa señalando que tal negativa supone acoger argumentos escépticos generales sobre la posibilidad del

conocimiento (p. 46). Las limitaciones propias del contexto jurídico —los plazos, los recursos, la intervención interesada de las partes— hacen que el conjunto disponible resulte epistemológicamente más pobre (Ferrer Beltrán, 2007, p. 46). Empobrecen el material, no la racionalidad de la operación que se practica sobre él. Las restricciones acotan el material; no autorizan a tratarlo con menor cuidado.

1.3.3. *La decisión y el estándar de prueba*

El tercer momento corresponde a la toma de la decisión. La valoración habrá permitido otorgar a cada hipótesis en conflicto un determinado grado de confirmación que nunca será igual a la certeza absoluta (Ferrer Beltrán, 2007, p. 47). Resta decidir si la hipótesis puede declararse probada con el grado de confirmación de que dispone, y eso depende del estándar de prueba que se utilice (Ferrer Beltrán, 2007, p. 47). La elección de uno u otro estándar es propiamente jurídica y se realiza en atención a los valores en juego en cada tipo de proceso (Ferrer Beltrán, 2007, p. 47). La epistemología suministra el grado y el derecho fija el umbral, y ninguna de las dos disciplinas puede suplir a la otra en esa división de tareas.

El autor enuncia entonces la tesis central de la distinción:

Conviene insistir en que el resultado de la valoración de la prueba que se obtenga en el segundo momento no implica por sí solo nada respecto de la decisión a adoptar. Para ello, es necesaria la intermediación de algún estándar de prueba. Y ni siquiera puede darse por descontado que la hipótesis que haya resultado más confirmada es aquella que deberá darse por probada. (Ferrer Beltrán, 2007, p. 48)

Entre la valoración y la decisión media, por tanto, una operación distinta de ambas. Consiste en contrastar el grado obtenido con una medida previamente fijada, y sin ella el tránsito de la una a la otra carece de justificación. La valoración informa la decisión, pero no la produce.

Esa operación intermedia no desaparece cuando el ordenamiento omite regularla. Un tribunal que declara probado o no probado un hecho ha aplicado necesariamente algún umbral, porque de otro modo no habría podido pasar del grado a la conclusión. La diferencia entre un sistema con estándar explícito y uno sin él no radica en que el segundo prescinda del umbral, sino en que lo aplica sin declararlo y, por ello, sin exponerlo a discusión. El material puede haber alcanzado un grado alto de confirmación y ser declarado insuficiente, o alcanzar uno bajo y ser declarado bastante, sin que ninguna de las dos decisiones resulte controlable. La arbitrariedad no consiste aquí en decidir mal, sino en decidir sin que nadie pueda

verificar contra qué se decidió, y la objeción alcanza por igual a las resoluciones que anulan y a las que confirman.

Ni siquiera cabe presumir que la hipótesis más confirmada sea la que deba tenerse por probada (Ferrer Beltrán, 2007, p. 48). El estándar penal de la duda razonable ilustra esa posibilidad, pues supone que la hipótesis de la culpabilidad no se tendrá por probada aunque cuente con más apoyo empírico que la de la inocencia, salvo corroboración muy alta (Ferrer Beltrán, 2007, p. 48). El umbral puede, en consecuencia, invertir el resultado de la valoración y no solo confirmarlo. Quien no lo enuncia se reserva un poder considerable, porque conserva la facultad de fijarlo después de conocer el grado alcanzado, y esa facultad es justamente la que un estándar explícito suprime.

La descomposición en tres momentos rinde, por último, un servicio diagnóstico que conviene dejar señalado. Cuando un tribunal declara que determinados elementos solo constituyen un indicio y que no se aportaron otros, comete errores que pertenecen al primer momento, porque describe mal el conjunto disponible. Cuando omite relacionarlos entre sí, el error pertenece al segundo. Y cuando concluye que el material no basta sin decir cuánto habría bastado, el error pertenece al tercero. Los tres defectos suelen presentarse juntos y confundidos bajo una misma fórmula de rechazo. Separarlos es la condición para nombrarlos, y nombrarlos es la condición para corregirlos, porque un instrumento diseñado para un momento no sirve para otro: exigir motivación donde falta prueba, o reclamar pruebas donde falta umbral, son errores de diagnóstico antes que de solución.

1.4. La inferencia probatoria tiene una estructura identificable

González Lagier (2005) se propone reconstruir el tipo de razonamiento por medio del cual se prueban los hechos de un caso, y llama a ese razonamiento inferencia probatoria (p. 53). La reconstrucción tiene una consecuencia práctica que justifica emprenderla: una operación cuya estructura puede describirse admite un control que la mera invocación de la sana crítica no permite. La estructura no determina el resultado de ninguna valoración concreta, pero fija qué debe aparecer en una sentencia para que la valoración pueda discutirse.

1.4.1. *Las dos fases y la cadena de inferencias*

González Lagier (2005) distingue, a efectos analíticos, dos fases dentro de la ambigua palabra prueba. La primera consiste en la práctica de las pruebas y en la obtención de información a partir de ellas, esto es, a partir de lo que dicen los testigos, los documentos y los peritos. La segunda consiste en extraer una conclusión a partir de la información obtenida en la primera (pp. 53-54). La primera fase establece las premisas del argumento que trata de probar una hipótesis, y la segunda realiza la inferencia que permite pasar de esas premisas a la conclusión. Obtener información y extraer de ella una conclusión son operaciones distintas, y confundirlas lleva a tratar como dato lo que ya es resultado de un razonamiento.

El razonamiento de la segunda fase rara vez consta de un solo paso. Puede ser muy complejo y constar de un encadenamiento de argumentos o inferencias parciales (González Lagier, 2005, p. 54). En el extremo inicial de la cadena figura la información obtenida directamente de las pruebas practicadas, y en el extremo final una hipótesis sobre lo ocurrido. Entre ambos extremos se sitúan premisas y conclusiones intermedias, cada una de las cuales resulta de una inferencia previa. La consecuencia metodológica es considerable: controlar una inferencia probatoria no consiste en examinar un salto único, sino en examinar cada eslabón de una cadena que puede ser larga. Un eslabón defectuoso compromete todo lo que pende de él, por sólido que sea el resto del razonamiento.

El autor ilustra el punto con un ejemplo que conviene reproducir por su precisión. Un policía declara que se encontró en la vivienda de Ticio un arma del mismo calibre que la que causó la muerte de Cayo. La información obtenida directamente es que el policía declara que el arma fue encontrada, no que realmente el arma fuera encontrada. Lo segundo ya es el resultado de la valoración de la fiabilidad de tal declaración, esto es, el resultado de un razonamiento y de una inferencia (González Lagier, 2005, p. 54). La observación parece obvia y no lo es. Entre el documento y el hecho media siempre una inferencia que suele quedar tácita, y de esa inferencia depende el valor de todo lo que se construya encima. Cuando un tribunal afirma que un acordeón impreso acredita la existencia de una estrategia de distribución, o cuando niega que la acredite, está resolviendo esa inferencia sin enunciarla.

1.4.2. Razones, garantía y respaldo

González Lagier reconstruye la inferencia probatoria con un esquema argumentativo de cuatro elementos, que atribuye a Toulmin. La pretensión es aquello que se sostiene y las razones son los datos que la apoyan. La garantía explica por qué esas razones apoyan esa pretensión, y el respaldo muestra la corrección o vigencia de la garantía. La garantía consiste siempre en una regla, norma o enunciado general. Los dos primeros elementos son particulares del caso y los dos últimos son generales, distinción que explica por qué unos se acreditan con pruebas y otros con argumentos. Los cuatro elementos deben estar presentes en toda argumentación, sea jurídica, científica o de la vida cotidiana (González Lagier, 2005, p. 56), y esa generalidad es lo que permite trasladar el esquema sin forzarlo a un ámbito determinado.

El traslado al razonamiento judicial sobre hechos resulta directo. Los hechos probatorios constituyen las razones del argumento, y los hechos a probar, la pretensión o hipótesis del caso. La garantía queda constituida por las máximas de experiencia, las presunciones y otros enunciados generales, que correlacionan el tipo de hechos señalado en las razones con el señalado en la pretensión. El respaldo queda configurado por la información necesaria para fundamentar la garantía (González Lagier, 2005, p. 57). La inferencia probatoria se deja describir, en consecuencia, como el paso de unos hechos probatorios a unos hechos a probar mediante una garantía apoyada en un respaldo. La descripción es sencilla, y por eso resulta utilizable como rejilla de lectura de cualquier sentencia: basta preguntar, ante cada conclusión fáctica, cuáles fueron las razones, cuál la garantía y cuál el respaldo.

Cada uno de los cuatro elementos puede faltar, y la falta de cada uno produce un vicio distinto. Si faltan las razones, no hay material sobre el cual razonar. Si falta la garantía, el paso de las razones a la pretensión queda sin justificar y solo cabe aceptarlo por autoridad. Si falta el respaldo, la garantía se afirma sin fundamento y puede ser una generalización arbitraria. Y si la pretensión no se enuncia con precisión, no se sabe qué se está probando ni, por tanto, cuándo quedaría probado. Exigir la exteriorización de los cuatro elementos permite localizar cuál de ellos falló, en lugar de descalificar el razonamiento en bloque.

La Suprema Corte llegó por su cuenta a una exigencia equivalente, aunque con otro vocabulario. Al fijar los requisitos de la inferencia lógica en la prueba indiciaria, estableció que de los hechos base acreditados debe fluir la conclusión

como consecuencia natural, con enlace directo entre unos y otra (Tesis 2004755, 2013). El enlace del que habla la Corte es la garantía del esquema. Añadió también que, cuando los mismos hechos probados permiten arribar a diversas conclusiones, el juzgador debe tener en cuenta todas ellas y razonar por qué elige la que estima conveniente (Tesis 2004755, 2013). Esa segunda exigencia no pertenece ya a la estructura de la inferencia sino a su contraste con hipótesis rivales. Doctrina y jurisprudencia convergen, en todo caso, sobre el mismo punto: el enlace debe mostrarse, no suponerse.

La jurisprudencia electoral mexicana ofrece, por su parte, un ejemplo poco advertido de garantía explícita. La Jurisprudencia 38/2002 no se limita a afirmar que las notas periodísticas arrojan indicios: enuncia la regla general que gradúa su fuerza. Cuando se aportan varias notas provenientes de distintos órganos de información, atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, y además no obra mentís del afectado, cabe otorgarles mayor calidad indiciaria. El criterio hace visible aquello que suele quedar tácito, porque enuncia la correlación entre el tipo de hecho probatorio y el tipo de hecho a probar. Es, en los términos del esquema, una garantía formulada por el propio tribunal, disponible desde 2002 y aplicable a cualquier material periodístico.

1.4.3. Las fuentes de la garantía

La garantía se desagrega en tres clases (González Lagier, 2005, p. 61). La primera son las máximas de experiencia, que a su vez se subdividen. Pueden ser de carácter científico o especializado, como las que aportan los peritos, o de carácter jurídico, como las derivadas del ejercicio profesional del juez. Pueden ser también de carácter privado, derivadas de las experiencias del juzgador al margen de su profesión. La segunda clase son las presunciones, que se establecen legal o jurisprudencialmente. La tercera son las definiciones o teorías, que suelen provenir de la doctrina, aunque también de la jurisprudencia o de la ley. La clasificación importa porque el respaldo exigible difiere en cada caso: una máxima científica se respalda con el dictamen pericial; una presunción jurisprudencial, con el precedente que la estableció; y una experiencia corriente, solo con la observación de casos anteriores.

La tercera clase merece una advertencia que el autor formula de inmediato. Cuando la unión entre los hechos probatorios y el hecho a probar viene dada por una teoría o una definición, el vínculo es conceptual. En ese supuesto no estamos en

sentido estricto ante un caso de prueba, sino ante uno de interpretación o calificación de los hechos (González Lagier, 2005, p. 61). La distinción resulta especialmente pertinente en materia electoral. Determinar si unos hechos acreditados constituyen coacción del voto, o si una irregularidad merece el calificativo de grave, no es una operación probatoria sino calificatoria. Confundir ambas permite presentar como insuficiencia de prueba lo que en realidad es un desacuerdo sobre la calificación, desplazamiento difícil de detectar cuando la garantía no se explicita, porque el lector no puede saber si el tribunal discute los hechos o su encuadre jurídico.

Las máximas de experiencia de carácter privado plantean el problema inverso y más frecuente. Al proceder de la experiencia corriente del juzgador, tienden a operar sin enunciarse, porque quien las emplea las considera evidentes. El artículo 16, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral remite de forma expresa a la experiencia como criterio de valoración, pero no exige que la máxima empleada se declare. Esa remisión sin carga de explicitación es una de las puertas por las que entra la discrecionalidad no controlable. Una máxima enunciada puede discutirse y refutarse; una máxima tácita solo puede intuirse a partir del resultado, de modo que la parte que quiera combatirla debe adivinarla primero.

Los hechos probatorios admiten, además, grados de interpretación, según se sitúen más cerca de lo meramente percibido o incorporen el sentido que se atribuye a lo percibido. Cuanto más se avanza en la cadena de razonamientos, más interpretados resultan los hechos probatorios, y pueden ser a su vez el resultado de otra inferencia del mismo tipo (González Lagier, 2005, p. 60). El material que sirve de base a los últimos eslabones no tiene, por tanto, la misma calidad epistémica que el de los primeros, y tratar todos los hechos probatorios como equivalentes ignora esa degradación progresiva. La prueba consiste entonces en el encadenamiento de varias inferencias sustancialmente análogas, y cada una de ellas reproduce la estructura de cuatro elementos. La conclusión converge con lo que la Suprema Corte estableció al fijar los alcances de la prueba indiciaria, pues la eficacia de la prueba circunstancial disminuye en la medida en que las conclusiones deban obtenerse a través de mayores inferencias y cadenas de silogismos (Tesis 2004753, 2013). Doctrina y jurisprudencia coinciden, así, en que la longitud de la cadena degrada el apoyo, lo que permite anclar una exigencia epistemológica en un criterio vigente del propio sistema mexicano.

De ese conjunto se sigue la tesis del apartado. Una inferencia probatoria cuya estructura permanece implícita no puede criticarse, porque no se sabe qué se está criticando. Quien impugna una valoración sin conocer la máxima de experiencia aplicada solo puede oponer su propia conclusión a la del tribunal, y el desacuerdo se vuelve irresoluble. Exteriorizar los cuatro elementos no obliga al juzgador a decidir de un modo determinado: le obliga a mostrar el recorrido, que es cosa distinta y mucho más modesta. Nada de ello excede, además, lo que el artículo 16, párrafo 1, ya presupone cuando remite a la lógica, la sana crítica y la experiencia. No se pide al juzgador nada que la ley no dé por supuesto; se le pide que lo escriba, que es la única forma de que un tercero pueda comprobarlo.

1.5. La solidez de la inferencia admite criterios de control

Describir la estructura de la inferencia probatoria no basta para controlarla, porque hace falta saber cuándo una inferencia resulta sólida y cuándo no lo es. González Lagier (2005) ofrece una respuesta articulada en once criterios, ordenados según el elemento de la estructura al que se refieren. Su virtud reside en que son verificables desde fuera de la sentencia, y su enunciación permite además algo que ningún umbral puede prescindir: si la solidez admite grados, entonces admite medida.

1.5.1. La vaguedad de la sana crítica

La doctrina procesal y la jurisprudencia superaron ya la lectura de la libre valoración como íntima convicción, y sostienen ahora que la valoración no puede ser una operación libre de todo criterio y cargada de subjetividad, sino una actividad sujeta a pautas. Debe someterse a las reglas de la lógica, a las de la sana crítica, a las de la experiencia, al criterio racional o al criterio humano (González Lagier, 2005, p. 79). La objeción decisiva es que se trata de referencias sumamente vagas y muy difíciles de concretar.

La coincidencia literal con la ley mexicana merece subrayarse, porque convierte la objeción en algo más que una discusión doctrinal ajena. El artículo 16, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral ordena valorar atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia. Son exactamente las tres fórmulas que González Lagier califica de sumamente vagas, de modo que el precepto mexicano no incurre en un defecto local sino que reproduce el estado general de la cuestión. El reproche que cabe

dirigir a la práctica jurisdiccional no consiste, por ello, en haber inventado una imprecisión, sino en no haberla resuelto pese a disponer de los materiales para hacerlo, y en haber tolerado durante casi tres décadas que la remisión legal operara en blanco, sin que ninguna resolución la dotara de contenido verificable.

Esa vaguedad admite reducción. Cabe dar criterios más concretos, o precisar qué son las reglas de la sana crítica, tomando algunas pautas de racionalidad epistemológica elaboradas para justificar las inducciones científicas (González Lagier, 2005, p. 80). La propuesta no elimina la vaguedad por completo, y el propio autor advierte que los criterios conservan un grado elevado de imprecisión. Reducirla representa, con todo, una ganancia considerable para quien deba impugnar una valoración ajena: un criterio impreciso pero enunciado puede discutirse, mientras que una remisión en blanco no admite discusión, porque no ofrece nada sobre lo que discrepar. Los once criterios que siguen se ordenan según se refieran a los hechos probatorios, a la garantía o a la hipótesis del caso.

1.5.2. Criterios sobre los hechos probatorios y sobre la garantía

El primer criterio interroga la fiabilidad, que depende de cómo se haya llegado a conocer los hechos probatorios (González Lagier, 2005, p. 81). Se distinguen tres vías de conocimiento: la observación directa del juez, las conclusiones científicas y el resultado de otra inferencia. Las dos primeras ofrecen mayor fiabilidad, pero en la mayor parte de los supuestos los hechos probatorios son conclusiones de otras inferencias previas. Que un testigo diga que oyó discutir a dos personas solo prueba de forma directa que el testigo lo dijo. Lo mismo sucede con un documento, pues habrá que inferir que su contenido es cierto (pp. 81-82). La declaración y el documento acreditan de forma inmediata su propia existencia, no la del hecho que refieren.

Esas inferencias intermedias, inevitables, pueden ser puntos débiles de la argumentación en su conjunto. De ahí una regla de graduación: la fiabilidad de los hechos probatorios es mayor cuanto menor es la cadena de inferencias que lleva hasta ellos. En sentido estricto la única prueba directa es la observación inmediata por el juez (González Lagier, 2005, p. 82). Todo lo demás resulta mediato en algún grado, de modo que la oposición entre prueba directa e indirecta describe una diferencia de grado y no de naturaleza.

El segundo criterio interroga la suficiencia: cuantos más hechos apunten en dirección a la hipótesis, mayor será la seguridad sobre su corrección. Sin embargo,

un solo hecho probatorio con alto grado de fiabilidad puede tener un peso mayor que varios hechos probatorios de escasa fiabilidad (González Lagier, 2005, p. 82). La suficiencia no se resuelve, por tanto, contando elementos, precisión especialmente pertinente para el derecho electoral, donde la exigencia de pluralidad probatoria suele formularse en términos numéricos. Contar pruebas y ponderarlas son operaciones distintas, y solo la segunda constituye valoración. Un tribunal que reprocha al promovente no haber aportado más elementos, sin examinar antes la fiabilidad de los que sí aportó, se detiene en la primera de esas dos operaciones y omite la segunda.

El tercer criterio interroga la variedad, y es el de mayor rendimiento para la prueba por indicios. La variedad de los hechos probatorios aumenta la probabilidad de la hipótesis que confirman, y su importancia radica en que permite la eliminación de las hipótesis alternativas con las que la principal entra en competencia (González Lagier, 2005, p. 83). El ejemplo que ofrece traslada bien al terreno electoral. Si los hechos contra un acusado de tráfico de droga se reducen a las acusaciones de vecinos con quienes mantiene pésimas relaciones, cabe pensar que la causa sea la animadversión. Esa hipótesis alternativa se debilita al encontrarse una balanza de precisión, y se debilita todavía más al hallarse en la balanza restos de cocaína (González Lagier, 2005, p. 84). Cada elemento nuevo cierra una vía de escape distinta.

El ejemplo suministra el fundamento epistemológico de la adminiculación. Lo que derrota a la hipótesis alternativa no es la acumulación de elementos del mismo tipo, sino la aparición de elementos de tipo distinto. Tres acusaciones más de los mismos vecinos no habrían debilitado en absoluto la explicación por animadversión, mientras que la balanza sí lo hace. El artículo 16, párrafo 3, al ordenar considerar los demás elementos que obren en el expediente, presupone exactamente esa lógica: la adminiculación no es una suma de valores probatorios, sino un procedimiento de eliminación de explicaciones rivales. La diferencia entre sumar y eliminar explica por qué un conjunto heterogéneo puede sostener aquello que ninguno de sus elementos sostiene por separado, y por qué la homogeneidad del material debilita la inferencia aunque aumente su volumen.

El cuarto criterio interroga la pertinencia, pues no todos los hechos sirven para confirmar una hipótesis, sino solo los que guardan relación con el hecho descrito en ella. Un hecho no será pertinente cuando no esté correlacionado con la hipótesis ni por presunciones ni por máximas de experiencia adecuadas y bien fundadas (González Lagier, 2005, p. 85). El criterio remite, por tanto, a la corrección

de la garantía, con lo que cierra el círculo abierto por la estructura de la inferencia. Sin garantía enunciada no puede determinarse la pertinencia de un elemento, y declarar impertinente una prueba sin explicitar la máxima aplicada produce una decisión que no admite control, porque el afectado no llega a saber qué correlación se consideró inexistente ni puede, en consecuencia, combatirla.

Dos criterios más recaen sobre la garantía misma. El primero pregunta si está suficientemente fundada. Las máximas de experiencia son la conclusión de una inducción ampliativa, por lo que no son necesariamente verdaderas sino probables. Su credibilidad racional depende de que esa inducción esté bien hecha, de modo que hay que examinar el fundamento cognoscitivo de las máximas y regularidades empleadas. No basta que la máxima aplicada esté bien fundada: debe también no haber máximas mejor fundadas que desautoricen el paso de los hechos probatorios a la hipótesis (González Lagier, 2005, p. 86). La exigencia obliga a considerar las regularidades que juegan en contra, y no solo las que favorecen la conclusión adoptada.

Las reglas construidas para la ocasión merecen advertencia aparte. Si la regla se elaboró para explicar el caso concreto que el juez debe decidir, entonces no se basa en una inducción ampliativa bien fundada. La máxima construida a la medida del caso resulta inservible, porque carece de la generalidad que es justamente lo que convierte a un enunciado en garantía. Las presunciones pueden verse como máximas de experiencia institucionalizadas y autoritativas y en esa medida deben apoyarse igualmente en una inducción sólida (González Lagier, 2005, p. 87). Una presunción jurisprudencial no queda exenta de fundamento por el hecho de provenir de un tribunal, aunque su carácter autoritativo limite el margen del juzgador para desplazarla.

El segundo criterio sobre la garantía pregunta por el grado de probabilidad causal que establece. Existen máximas que correlacionan dos fenómenos con alta probabilidad y máximas que establecen esa correlación con una probabilidad sensiblemente menor. Cuanto menor sea el grado de probabilidad causal expresado por la máxima de experiencia, menor será la probabilidad inferencial con la que se sigue la hipótesis final (González Lagier, 2005, pp. 87-88). La regla tiene aplicación inmediata en materia electoral. Afirmar que quien aparece en un impreso de propaganda obtuvo por ello más votos supone una máxima de probabilidad causal baja, y la conclusión hereda esa debilidad. Enunciar la máxima obliga a reconocer el límite de la inferencia; omitirla permite presentar como fuerte un razonamiento que

no lo es, y el vicio opera en las dos direcciones, porque también permite descartar por débil lo que la máxima sostendría.

1.5.3. Criterios sobre la hipótesis y gradualidad de la solidez

El primer criterio sobre la hipótesis pregunta si ha sido refutada. Se distinguen dos formas de refutación (González Lagier, 2005, p. 88). Una hipótesis queda refutada de manera directa cuando su verdad resulta incompatible con otra afirmación que se ha dado por probada, y de manera indirecta cuando implica una afirmación que se demuestra falsa o poco probable. La exigencia opera con independencia del apoyo que la hipótesis haya recibido de los hechos probatorios, de modo que la confirmación no dispensa de comprobar la ausencia de refutación. Confirmación y ausencia de refutación son condiciones distintas, y la segunda no se sigue de la primera: una hipótesis muy apoyada puede quedar destruida por un solo hecho incompatible con ella.

El segundo criterio pregunta si se han confirmado las hipótesis derivadas, que refutan la principal cuando se demuestran falsas y aumentan su credibilidad cuando se confirman como verdaderas (González Lagier, 2005, p. 90). El tercero, y el más exigente, pregunta si se han eliminado las hipótesis alternativas: cuando pueden eliminarse todas las que compiten por explicar un hecho, salvo una, esa debe tomarse como verdadera (González Lagier, 2005, p. 90). El autor advierte de inmediato que se trata de un ideal rara vez alcanzable en un proceso judicial, donde lo usual es disponer de varias hipótesis y escoger la que resiste mejor los intentos de refutación (González Lagier, 2005, p. 90). La exigencia realista no consiste, por tanto, en la eliminación total de las alternativas, sino en la comparación razonada entre aquellas que subsisten tras el examen.

De ese tercer criterio deriva una regla de graduación de alcance general: la credibilidad de una hipótesis disminuye cuantas más hipótesis alternativas subsistan (González Lagier, 2005, pp. 90-91). La formulación convierte la refutación en un factor de grado y no en un requisito binario, de manera que no se trata de eliminar toda alternativa concebible sino de reducir el número de las que siguen en pie. La Suprema Corte alcanzó una conclusión equivalente al exigir que el juzgador tenga en cuenta todas las conclusiones posibles y razone por qué elige la que estima conveniente (Tesis 2004755, 2013). Doctrina y jurisprudencia coinciden en que la elección entre hipótesis debe justificarse y no simplemente declararse, lo que

permite exigir ese razonamiento con apoyo en criterio vigente del sistema mexicano y no únicamente en doctrina extranjera.

Los dos criterios restantes operan como reglas de desempate. El cuarto es la coherencia, que presenta un aspecto interno de congruencia entre los enunciados que integran la hipótesis y otro externo de congruencia con el resto del conocimiento disponible (González Lagier, 2005, p. 91). El quinto es la simplicidad, según el cual las hipótesis más simples son las que explican más con un menor número de presuposiciones (González Lagier, 2005, p. 91). Ambos sirven únicamente para escoger entre hipótesis que cuentan con un grado de confirmación semejante, y su función es por tanto subsidiaria. Ninguno de los dos suple la falta de apoyo empírico, de modo que una hipótesis coherente y simple pero desprovista de confirmación sigue siendo una conjetura, por elegante que resulte su formulación.

La solidez de la inferencia probatoria es gradual en dos sentidos distintos, advertencia que el autor formula al introducir los once criterios y que pesa tanto como ellos (González Lagier, 2005, p. 80). En una inferencia dada pueden estar presentes más o menos criterios, y la ausencia de alguno no constituye por sí sola razón para rechazarla; casi todos los criterios pueden cumplirse, además, en mayor o menor medida (González Lagier, 2005, p. 80). Esa doble gradualidad impide convertir los once criterios en una lista de requisitos cuya falta invalide la inferencia. Los criterios describen un espectro y no un umbral, y confundirlos llevaría a un formalismo tan rígido como el sistema de prueba tasada que la libre valoración vino a superar.

Una lista de requisitos sustituiría la libre valoración por una prueba tasada de nuevo cuño; una rejilla de exteriorización deja intacta la libertad valorativa y suprime únicamente su opacidad. El juzgador conserva íntegra la facultad de apreciar el material probatorio y pierde solo la de no explicar cómo lo apreció. Los criterios permiten decir, en definitiva, cuán sólida es una inferencia, pero no permiten decir cuán sólida debe ser, porque esa segunda pregunta ya no pertenece a la epistemología sino al derecho y se responde en atención a los valores en juego en cada tipo de proceso.

1.6. El conjunto probatorio excede la suma de sus elementos

El artículo 16, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral ordena atender a los demás elementos que obren en el expediente. Ordena también atender a la relación que esos elementos guardan

entre sí, y ese segundo mandato presupone que el conjunto aporta algo que sus elementos aislados no aportan. El presupuesto tiene fundamento, aunque no del modo que el holismo narrativo sugiere, y precisar esa diferencia resulta indispensable para que la valoración relacional resista la objeción más seria que puede dirigírsele.

1.6.1. Las objeciones al tratamiento aislado de los elementos de prueba

Amaya (2015) reconstruye el debate entre atomismo y holismo en la teoría de la prueba y recoge tres objeciones dirigidas contra el primero. La primera sostiene que la prueba de todo caso controvertido se compone de elementos pertenecientes al menos a dos relatos contradictorios, uno falso y otro verdadero, que aparecen entremezclados. Solo al adoptar la decisión final cabe identificar cuáles de esos elementos pertenecen al relato verdadero y cuáles al falso. De ahí que resulte ilógico asignar un valor de verdad o de probabilidad a un elemento aislado antes de la decisión, que es precisamente lo que el atomismo exige (Amaya, 2015, p. 94). La objeción apunta a un problema de orden: el atomismo pretende resolver al principio lo que solo puede resolverse al final, cuando ya se conoce a qué relato pertenece cada pieza.

La segunda objeción resulta la más pertinente para el derecho electoral mexicano. En la medida en que los elementos de prueba están enlazados entre sí formando un todo conectado, ningún elemento debe tratarse de manera aislada respecto de los demás, contra lo que el atomismo requiere. La formulación describe con exactitud la operación que el artículo 16, párrafo 3, ordena cuando manda atender al recto raciocinio de la relación que los elementos guardan entre sí. La tercera objeción sostiene que el enfoque atomista socava el carácter fáctico de la prueba judicial, al convertir los hechos en proposiciones inferidas de la experiencia general, con lo que desatiende indebidamente las circunstancias del caso concreto (Amaya, 2015, pp. 94-95). Las tres convergen en un mismo reproche: tratar cada elemento por separado destruye información que solo existe en la relación entre ellos.

Conforme a la versión del holismo que Amaya expone, no cabe extraer conclusiones fácticas a partir de elementos de prueba aislados, por notables que resulten. El juzgador debe ponderar la prueba y alcanzar una conclusión solo después de haber examinado el conjunto del material del caso (Amaya, 2015, p. 95). El enunciado tiene consecuencias prácticas inmediatas para el control de las

sentencias, porque declarar que un elemento no acredita nada por sí solo es compatible con que el conjunto al que pertenece sí acredite algo. Confundir ambas afirmaciones produce un vicio característico y fácil de identificar: la sentencia que sostiene que los elementos aportados solo constituyen un indicio delata en el singular de esa fórmula la operación realizada, pues dos pruebas de origen distinto quedan reducidas a una sola unidad de valoración y con ello desaparece la relación que las une.

1.6.2. Los anclajes del derecho mexicano

La objeción no es ajena a la tradición jurídica mexicana, ni reciente en ella. La Suprema Corte la formuló con notable economía hace más de medio siglo. Estableció que la prueba indiciaria resulta de la apreciación en su conjunto de los elementos probatorios que aparezcan en el proceso, y que esos elementos no deben considerarse aisladamente (Tesis 235868, 1974). Añadió que de su armonía lógica, natural y concatenamiento legal habrá de establecerse una verdad resultante, que conduzca de manera unívoca e inequívoca a la verdad buscada (Tesis 235868, 1974). La coincidencia con el planteamiento holista es notable, sobre todo por la distancia temporal y disciplinar que separa ambas formulaciones. Una tesis aislada de la Séptima Época y la teoría contemporánea de la prueba coinciden en rechazar el tratamiento fragmentario del material probatorio, de modo que el criterio mexicano no requiere actualización doctrinal: requiere aplicación.

La jurisprudencia electoral llegó al mismo punto por su propia vía. La Jurisprudencia 19/2008 sostiene que el proceso se concibe como un todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia de actos que se desarrollan progresivamente. De ese carácter unitario deriva que la fuerza convictiva de los medios de prueba deba valorarse en relación con las pretensiones de todas las partes, y no solo del oferente. El criterio se enunció bajo el rótulo de la adquisición procesal, pero su alcance excede esa figura, porque afirma que el expediente constituye una unidad, que es exactamente la premisa que la segunda objeción al atomismo defiende. El sistema mexicano dispone, por tanto, de dos anclajes propios para exigir la valoración conjunta. A ellos se suma la Jurisprudencia 4/2014, que impone adminicular la prueba técnica con otro elemento que la perfeccione o corrobore, con lo que presupone que la relación entre elementos produce un valor del que carecen por separado.

1.6.3. Los riesgos del holismo y el dominio de cada modelo

El holismo ha recibido objeciones serias que conviene asumir en lugar de esquivar. La primera sostiene que las teorías coherentistas están seriamente subdesarrolladas, y que conceptos clave como plausibilidad y coherencia se emplean de manera imprecisa. La consecuencia es grave: las teorías holistas no proporcionan un criterio claro para escoger entre explicaciones alternativas de los hechos en competencia. Una teoría que no ofrece criterio de elección resulta inservible como fundamento de cualquier método de valoración, porque un método necesita precisamente eso. La objeción no es menor ni externa: proviene de autores simpatizantes del propio holismo.

La segunda objeción advierte sobre los riesgos del enfoque que considera el caso como un todo. Los relatos pueden emplearse para introducir de contrabando consideraciones irrelevantes y para desviar la atención de las debilidades del argumento. Sirven también para apelar a la emoción antes que a la razón y para recurrir a prejuicios o estereotipos ocultos. Los relatos son sin duda necesarios, pero peligrosos (Amaya, 2015, p. 125). El riesgo tiene traducción electoral evidente, pues una narración coherente sobre una elección irregular puede resultar persuasiva sin que ninguno de sus elementos esté acreditado. Lo mismo cabe decir de la narración contraria, que presenta el proceso como impecable apoyándose en la sola regularidad formal de sus etapas. El peligro opera, por tanto, en ambas direcciones.

Taruffo figura entre quienes formulan esa advertencia. Amaya (2015) recoge que el autor previene contra los peligros de adoptar un enfoque holista, porque sugiere decidir con base en algo distinto de las pruebas, de modo que las teorías holistas desatenderían problemas como la definición del hecho, la relevancia de la prueba y la carga probatoria. En su propia obra Taruffo (2013) resulta todavía más tajante, pues considera inatendible y desviante la perspectiva holística propuesta por algunos exponentes del narrativismo judicial (p. 59). La objeción no admite despacho rápido y obliga a precisar con cuidado qué se toma del holismo y qué se deja fuera.

La salida de la disyuntiva la ofrece, dentro de la propia exposición de Amaya, el enfoque conciliador de Tillers, cuyo propósito no consiste tanto en defender una versión del holismo como en reconciliar holismo y atomismo. Ninguno de los dos permite ofrecer un retrato fiel del razonamiento sobre hechos en el derecho. El enfoque atomista pasa por alto que el significado de la prueba se adhiere a veces al conjunto del material, y tanto el análisis atomista como las apreciaciones holistas

desempeñan, en consecuencia, un papel importante en la inferencia jurídica. Ningún modelo por sí solo la describe de manera completa, de modo que un retrato de la inferencia racional exige recurrir a varias teorías de la prueba lógicamente dispares (Amaya, 2015, pp. 95-96).

La cuestión correcta no consiste, por tanto, en determinar si un modelo de inferencia es o no correcto, sino en determinar cuál es el dominio propio de cada uno (Amaya, 2015, p. 97). Formulada así, la disputa entre atomismo y holismo deja de ser una elección entre doctrinas rivales y se convierte en un problema de asignación, consistente en determinar qué operación corresponde a cada fase del razonamiento probatorio. La reformulación permite conservar lo que el holismo aporta sin incurrir en los riesgos que sus críticos denuncian, y permite además no contradecir a quienes lo rechazan como método único de decisión, porque la objeción de esos autores recae sobre un uso del holismo que aquí tampoco se defiende.

La reconciliación se confirma al examinar lo que el propio Taruffo exige. Pese a rechazar la perspectiva holística, sostiene que debe establecerse el grado de confirmación que cada prueba atribuye al enunciado, y que a partir de ahí ha de determinarse el grado global o de conjunto de corroboración que ese enunciado recibe de todas las pruebas que lo atañen (Taruffo, 2013, p. 59). La exigencia de un grado de conjunto es, sin más, una exigencia de valoración relacional, por mucho que el autor la formule desde una perspectiva analítica. Lo que Taruffo rechaza no es atender al conjunto, sino sustituir el examen de cada elemento por la impresión global de coherencia narrativa. Su posición y la segunda objeción al atomismo resultan, así, compatibles entre sí, y ambas sostienen el mandato del artículo 16, párrafo 3.

La adminiculación queda así gobernada por una regla precisa. Es una agregación analítica y no una apreciación narrativa: exige valorar primero cada elemento y determinar después el grado de corroboración que el conjunto confiere a la hipótesis. La secuencia responde a la fórmula que Ferrer Beltrán expresa al exigir la valoración individual y en conjunto, y no autoriza a sustituir el examen de los elementos por la elección del relato más convincente. Con esa delimitación, el mandato del artículo 16, párrafo 3, queda a salvo de la objeción de Taruffo y conserva el fundamento epistemológico que le suministra la eliminación de hipótesis alternativas. El conjunto probatorio excede la suma de sus elementos porque cierra vías de escape, no porque componga un relato más agradable.

1.7. *Libre convicción como principio metodológico negativo; la sana crítica no es criterio*

Tanto la Suprema Corte como la jurisprudencia electoral mexicana remiten a la «libre convicción» y a la «sana crítica» como fundamentos de la valoración. Ambas expresiones sugieren, a primera vista, que el juzgador goza de discreción amplia para decidir conforme a su conciencia. Ninguna de las dos significa eso. La «libre convicción» es un principio metodológico negativo que rechaza el apriorismo legal, pero no un criterio positivo de valoración, y la «sana crítica» nunca fue un criterio sustantivo sino una referencia a máximas de experiencia. La confusión entre el significado originario de ambas y sus usos posteriores está en el origen de un problema de controlabilidad de las sentencias.

1.7.1. *Principio negativo y criterio positivo*

La distinción entre uno y otro ha quedado opacada por el uso indiferenciado de ambas expresiones. Gascón (2010) la traza con precisión al examinar la historia de la libre convicción en el derecho procesal. El rechazo de la prueba legal fue un giro revolucionario, pues la prueba legal predeterminaba el valor de cada medio mediante reglas abstractas: el testigo presenciador, la confesión espontánea, el documento público, cada uno tenía un peso fijo establecido por la ley. La libre convicción fue la reacción contra ese sistema fetichista, y su propósito consiste simplemente en «el rechazo de las pruebas legales como suficientes para determinar la decisión» (Gascón, 2010, p. 142). Con esa precisión, la libre convicción no es un criterio positivo que diga cómo debe valorarse, sino un principio *negativo* que deshace el camino contrario: prescribe que el juzgador *no* está sujeto a tasaciones previas.

La diferencia tiene consecuencias prácticas decisivas, porque un principio negativo deja sin resolver la cuestión de cómo proceder una vez rechazado el apriorismo legal. Una vez que la ley no fija el valor de la prueba, el juzgador debe determinar ese valor mediante algún método. La libre convicción marca dónde no se puede estar —bajo la coacción de reglas legales— pero no marca dónde se debe estar: «la libre valoración no puede interpretarse más que en su significado primigenio: un *principio metodológico (negativo)*. Pero un principio metodológico y sólo eso. No, por tanto, un *criterio (positivo)* de valoración» (Gascón, 2010, p. 142). La línea que separa ambas cosas es la que separa lo permitido de lo prescrito: la

libre convicción permite al juzgador desligarse de reglas apriorísticas, pero no prescribe cómo decidir sin ellas. Confundirlas convierte un límite al formalismo en autorización para la arbitrariedad.

1.7.2. *La deriva subjetivista*

El uso posterior de la libre convicción se apartó de ese significado originario. En lugar de entenderse como rechazo del apriorismo legal, pasó a interpretarse como «valoración libre, sin sujeción a reglas de ningún tipo» (Gascón, 2010, p. 142). Con ese cambio de significado, la libre convicción dejó de ser una garantía epistemológica y se convirtió en una puerta abierta a la subjetividad descontrolada. La gravedad de la deriva no es apreciación aislada: Ferrajoli no duda en calificarla como «una de las páginas políticamente más amargas e intelectualmente más deprimentes de la historia de las instituciones penales» (Gascón, 2010, p. 34). El juzgador recibía el encargo de «decidir según su conciencia» o según su «íntima convicción», pero sin instrucción acerca de cómo formar esa convicción racionalmente.

Nieva Fenoll (2015) describe el resultado con economía. Una vez rechazadas las reglas de la prueba legal, el juez «se deja solo, a fin de que haga lo que haya de hacer a su libre albedrío, lo que significa que su juicio estarán muchas veces imperfecto, o difícilmente motivable por estar con frecuencia basado en intuiciones derivadas de una experiencia no siempre bien aprehendida, a falta de otros datos en que apoyarse» (Nieva Fenoll, 2015, p. 90). La observación apunta al mismo problema que la distinción de Gascón: en ausencia de criterios positivos, el juzgador no queda liberado sino desorientado.

Lo ocurrido en la jurisprudencia penal angloamericana confirma que la deriva no es privativa de la tradición continental. Laudan (2005) registra que a través del siglo XX la «duda razonable» —que en su origen significó una medida epistémica precisa relacionada con la epistemología de Locke— fue deliberada y lentamente desplumada hasta quedar reducida a «un "careces de toda duda", esto es, a tener una alta confianza subjetiva» (Laudan, 2005, p. 99). La forma jurídica se mantuvo, pero el contenido se evaporó, y lo que quedó en su lugar fue precisamente lo que la libre convicción no era en su origen: la convicción íntima del juzgador, inaprensible, incomunicable, imposible de verificar. El estándar se vuelve así parasitario de su propia base, pues el jurado debe determinar si la culpabilidad se ha probado sin regla que le diga cuándo ha alcanzado esa convicción (Laudan, 2005, p. 106).

La convergencia entre ambas tradiciones es más profunda de lo que su distinto vocabulario sugiere. El subjetivismo es la base del sistema, aunque eso sea lo mismo que no decir nada: «en realidad, las frases construidas por la doctrina alemana en nada se diferencian de los estándares de prueba anglosajones. No orientan a jurados, sino a jueces, pero su finalidad es exactamente la misma» (Nieva Fenoll, 2015, p. 92). Si todos los jueces declaran tener «convicción» pero ninguno especifica en qué consiste, entonces no existe criterio verificable de que todos apliquen el mismo. La apariencia de uniformidad oculta divergencias imposibles de detectar.

1.7.3. La sana crítica y la exigencia de explicitación

Algo parecido ocurre con la «sana crítica», aunque su historia sea distinta. La expresión, que remite a la «buena conciencia» medieval, aparece en fuentes españolas desde el siglo XIX como alternativa discreta al lenguaje de la «libre convicción», y nunca fue un criterio sustantivo sino una referencia poco precisa a máximas de experiencia. El artículo 317 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 disponía que los jueces valorarían las declaraciones testificales «según las reglas de la sana crítica», pero esa referencia «no aporta mucho en toda esta materia» (Nieva Fenoll, 2015, p. 88), porque no especifica qué reglas son las de la sana crítica ni cómo aplicarlas.

El problema no es que la expresión sea incorrecta, sino que es demasiado vaga. «De Vicente y Caravantes valoró la referencia legal a la sana crítica como una obligación del juez de apreciar, además de otras máximas de experiencia sociológicas, las facultades psicológicas de los testigos» (Nieva Fenoll, 2015, p. 89). La sana crítica se entendía, entonces, como la aplicación de máximas de experiencia psicológicas y sociológicas a la valoración de la prueba. Eso es todo cuanto fue y todo cuanto puede ser: no proporciona un método, ni siquiera una orientación clara, y solo apunta en la dirección correcta de que el juzgador use el juicio para aplicar máximas de experiencia. La práctica posterior la convirtió, sin embargo, en un sinónimo vagamente tranquilizador de «el juez decide como considera conveniente». La doctrina española de los siglos XVII a XIX «fue bien consciente de este problema, aunque con motivaciones que ensobrecieron la etología del problema y, por tanto, su solución» (Nieva Fenoll, 2015, p. 89), porque temían que un criterio estricto menguase la autoridad del juez.

Una valoración que no puede describirse no puede discutirse, y una sentencia que no expone la valoración que realiza deja al lector sin forma de verificar si la decisión resultó de la aplicación de criterios o de pura arbitrariedad. El artículo 16, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral no se limita, por ello, a remitir a la libre convicción: conjuga tres estándares, al ordenar valorar conforme a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia. Ese triple anclaje importa, porque no es lo mismo remitir a uno solo. La lógica proporciona criterios verificables, pues una conclusión que contradice sus premisas es lógicamente falsa y eso puede demostrarse. Las máximas de experiencia pueden enunciarse y discutirse, aunque su aplicación en el caso concreto admita debate. La experiencia del juzgador, por último, es un factor inevitable que debe quedar supeditado a los dos primeros. El problema comienza cuando cualquiera de los tres se interpreta como sinónimo de convicción íntima y queda entonces exonerado de justificación.

La salida no consiste en obligar al juzgador a decidir de un modo determinado ni en negarle su experiencia y su juicio, sino en hacer que lo escriba: que comunique qué regla lógica aplicó, cuál fue la máxima de experiencia y por qué la consideró aplicable, y qué peso confirió a su propia experiencia frente a las pruebas que la contradicen. La libre convicción, como principio negativo, seguirá siendo tan libre como siempre. Dejará únicamente de ser convicción íntima para convertirse en convicción justificada, y eso —solo eso— es lo que la hace compatible con el Estado de derecho.

1.8. Un estándar subjetivo no es un estándar

Si la libre convicción es un principio negativo que rechaza la tasación legal, y si la sana crítica nunca fue un criterio sustantivo, queda por saber qué ocupa el lugar vacante. La respuesta usual es que queda la «convicción íntima» o la «confianza subjetiva» del juzgador. Esa respuesta no resuelve el problema: una convicción subjetiva no puede funcionar como estándar de prueba, porque le falta precisamente lo que todo estándar debe tener.

1.8.1. Los tres atributos de un estándar

Laudan (2005) comienza por lo elemental. Un estándar de prueba, para cumplir su función, debe proporcionar al juzgador una regla que le permita determinar cuándo

ha alcanzado la certeza suficiente para decidir. Esa exigencia presupone tres cosas: una medida, algo que pueda comunicarse y algo que pueda verificarse. La «íntima convicción» carece de las tres. No es una medida porque la convicción personal es privada y variable de un juez a otro. No puede comunicarse porque consiste en un estado emocional o cognitivo interno que cada persona experimenta de forma distinta. Y no puede verificarse porque no hay criterio externo que permita a un tercero saber si la convicción de un juez es genuina, o si alcanza el nivel que el sistema presupone (p. 95).

Frente a esa carencia, un estándar verdadero debe ser capaz de cumplir dos operaciones. La primera consiste en guiar al juzgador durante el proceso de deliberación, indicándole cuándo ha reunido prueba suficiente. La segunda consiste en permitir que terceros —las partes, los órganos de apelación, la opinión pública— verifiquen que el juzgador aplicó el estándar correctamente. Una convicción subjetiva no satisface ninguna de las dos. No puede guiar porque no existe instrucción que defina qué es una «convicción», ni cuándo se alcanza, ni cómo se distingue de un mero presentimiento. Y no puede verificarse porque el resultado —la sentencia que declara al acusado culpable o inocente— es el único dato disponible, y ese dato no revela si la convicción que la motiva es auténtica o si basta para justificar la decisión (Laudan, 2005, p. 95).

1.8.2. La corrupción de la duda razonable y las dos vías convencionales

La historia del derecho procesal penal anglo-estadounidense registra ese proceso de degradación, según documenta Laudan (2005). El estándar oficial es la «duda razonable», expresión que en su origen significaba una medida epistemológica precisa, relacionada con la epistemología de Locke y el cálculo de probabilidades. A lo largo del siglo XX, sin embargo, fue deliberada y lentamente desplumada de su contenido epistemológico, hasta llegar a significar simplemente «tener una alta confianza subjetiva acerca de la culpabilidad» (p. 99). La forma jurídica se mantuvo —los jueces siguen pronunciando las palabras «más allá de una duda razonable»—, pero el contenido se evaporó, y lo que quedó en su lugar fue la convicción íntima del juzgador.

El estándar se volvió así parasitario de su propia base: el jurado debe determinar si la culpabilidad se ha probado, pero sin regla que le diga cuándo ha alcanzado esa convicción (Laudan, 2005, p. 106). En esas circunstancias, «hoy en día, el punto de vista oficial de la Corte Suprema es que una condición necesaria y

suficiente para condenar al acusado en un juicio penal es una creencia firme de la culpabilidad por parte del jurado» (Laudan, 2005, p. 99). Pero esa creencia nunca se especifica. Los jueces y juristas académicos no reciben instrucción sobre qué significa «creencia firme», ni sobre cómo distinguirla de una creencia débil, ni sobre cuál es el umbral que la separa de la duda.

Dos intentos históricos de definir un estándar de prueba en el derecho penal, uno cualitativo y otro cuantitativo, han pretendido llenar ese vacío. El primer camino requiere que el juzgador tenga una «certeza moral» o «convicción que va más allá de la duda razonable» de que el acusado cometió el delito. El segundo, de corte académico-bayesiano, propone en su lugar un nivel de probabilidad —generalmente entre el 90% y el 95%— que debe alcanzarse antes de condenar (Laudan, 2005, p. 98). Ninguno de los dos es satisfactorio, y conviene ver por qué falla cada uno.

En el primero, la dificultad radica en que la noción de «certeza moral» o «convicción» es ella misma subjetiva. Cuando Laudan pregunta qué significa que un jurado esté «completamente persuadido», la respuesta que recibe es que depende de la creencia privada de cada jurado. Dos jurados pueden estar igualmente seguros de la culpabilidad —uno asignando una probabilidad de 90%, otro de 95%— y ambos pueden declarar que tienen «confianza» en esa estimación, sin que exista modo de saber cuál de ellos aplicó el estándar correctamente. Si el estándar es la duda razonable, la pregunta se reduce a esto: «¿estás completamente persuadido de que él lo cometió?» Si, por el contrario, han sido abogados académicos quienes han establecido que el estándar es del 90%, la pregunta que debe hacerse es: «¿tu evaluación de la probabilidad de culpabilidad es mayor del 90%?» (Laudan, 2005, p. 104). Las dos preguntas son radicalmente distintas, y la respuesta depende de cuál sea la que se plantee.

El camino cuantitativo tropieza con un obstáculo diferente. Incluso si se estableciera de forma explícita que el estándar es una probabilidad de 95%, esa precisión no eliminaría la subjetividad de la estimación inicial. El siguiente ejemplo lo ilustra. Si un juez comienza un caso asignando una probabilidad previa de inocencia de 95%, y después examina la evidencia, llega a una estimación final de probabilidad de culpabilidad que depende de sus creencias iniciales acerca de si el acusado es culpable o inocente. Si otro juez comienza el mismo caso con una presunción de inocencia de 50%, su estimación final será más alta. En ambos casos, el resultado dependerá «entre otras cosas, de las creencias subjetivas iniciales del jurado acerca de la culpabilidad e inocencia» (Laudan, 2005, p. 101). La

precisión numérica oculta una multiplicidad de creencias subjetivas que operan bajo la superficie.

1.8.3. *Uniformidad y distribución del error*

El defecto que afecta a ambas vías es que hacen depender el estándar de datos que no pueden uniformarse. En un sistema donde el estándar de prueba es la convicción subjetiva del juzgador respecto de la culpabilidad, la determinación de cuándo se ha satisfecho «dependerá inevitablemente, entre otras cosas, de las creencias subjetivas iniciales del jurado acerca de la culpabilidad o inocencia» (Laudan, 2005, p. 101). Dos jueces enfrentados a exactamente la misma evidencia pueden aplicar lo que creen es el mismo estándar y llegar a conclusiones completamente opuestas, sin que exista criterio alguno para resolver el desacuerdo: en un sistema con estándares subjetivos, las pruebas que pueden convencer a uno de la culpabilidad de otro no van a persuadir a un tercero de esa culpabilidad, de modo que no cabe esperar «ni uniformidad ni justicia si cada juez utiliza sus propios criterios» (p. 95). La apariencia de uniformidad oculta divergencias imposibles de detectar.

La subjetividad incapacita al estándar en un nivel todavía más profundo. Laudan (2005) sostiene que el único mecanismo para distribuir errores en favor del acusado es un estándar no subjetivo de la prueba, y que si se sitúa ese estándar en la altura correcta capturará completamente las creencias compartidas acerca de la razón apropiada de absoluciones falsas a condenas falsas (p. 112). Una regla de prueba que funciona verdaderamente cumple, así, una tarea de ingeniería social: especifica de antemano cuál es la proporción de errores que la sociedad está dispuesta a tolerar y vincula después el comportamiento del juez a esa proporción.

Esa tarea solo es posible si el estándar es independiente de la psicología individual del juez. Cuando el estándar es la convicción íntima o la confianza subjetiva, el sistema renuncia a esa capacidad, y lo que queda es un estándar parasitario del nivel de confianza que el investigador tenga respecto de la culpabilidad del acusado (Laudan, 2005, p. 106). No hay forma de saber de antemano cuál será el resultado, porque depende de datos que no pueden controlarse: las creencias privadas de cada juez acerca de lo que es probable o seguro.

Si el estándar de prueba fuese formulado en términos de una probabilidad específica, sería casi seguro que muchos de los jurados que han decidido que el acusado cometió el delito estarían en apuros para determinar, de una manera que

no sea meramente arbitraria, si su confianza en la culpabilidad satisfizo o no las demandas impuestas por ese estándar (Laudan, 2005, p. 103). La razón es que la confianza subjetiva no se mide: nadie sabe cuánto de confianza es «90%» en términos de la experiencia vivida. Si no puede especificarse, tampoco puede verificarse, y si no puede verificarse no es un estándar sino una excusa.

Para que un estándar funcione debe comunicar algo más que una invitación a decidir conforme a la propia conciencia: debe decir, de forma precisa, cuándo se ha alcanzado la certeza suficiente. Mientras ese decir quede implícito o privatizado en la mente del juzgador, el derecho a impugnar queda convertido en derecho a adivinar. Las partes no saben qué tenían que probar, y los jueces de apelación no saben qué tenían que revisar.

1.9. *Motivación como control externo de la inferencia*

Una inferencia con estructura descriptible, criterios de solidez enunciabiles y un conjunto probatorio que debe valorarse de forma relacional siguen siendo operaciones invisibles mientras nada obligue al juzgador a exteriorizarlas. La motivación es el mecanismo que las vuelve visibles, y no se trata de un requisito formal añadido al final de la sentencia sino de la condición que convierte la valoración en una actividad controlable.

1.9.1. *La garantía de cierre y sus dos funciones*

Conviene comenzar por el diagnóstico que justifica la exigencia. Andrés Ibáñez (1992) localiza con precisión el punto ciego de la función jurisdiccional: la *quaestio facti* es el momento de ejercicio del poder judicial por antonomasia, porque es en la reconstrucción o en la elaboración de los hechos donde el juez es más soberano, más difícilmente controlable, y donde, por ende, puede ser más arbitrario (p. 261). El juicio de hecho es tan problemático o más que el juicio de derecho, y en él la discrecionalidad del juzgador es mayor que en la interpretación de las normas, pese a que esa discrecionalidad haya pasado por alto a la mayoría de los juristas (Gascón, 2010, p. 174). El desequilibrio es notable: la zona donde el poder judicial es más libre es también aquella sobre la que la cultura jurídica ha producido menos controles.

Frente a esa zona, la motivación opera como el instrumento que impide que la libertad valorativa se convierta en arbitrio. Andrés Ibáñez (1992) recupera la fórmula

de Calamandrei, para quien la motivación constituye el signo más importante y típico de la racionalización de la función judicial, y precisa por qué funciona: el simple hecho de ampliar el campo de lo observable de la decisión, no sólo para los destinatarios directos sino al mismo tiempo e inevitablemente para terceros, comporta la exigencia de un plus de justificación del acto y una mayor exposición de éste a la opinión (pp. 257-258). No es la sanción lo que disciplina, sino la exposición.

Si valorar consiste en verificar enunciados fácticos, entonces «el principio valorativo de la libre convicción no tiene sentido si no se conecta a su vez con la exigencia de motivación, de explicitación de las razones que apoyan la verificación de esos enunciados, pues en otro caso la libre valoración se convertiría en valoración libre, discrecional, subjetiva y arbitraria» (Gascón, 2010, p. 175). La distinción entre valoración libre y libre valoración no es un juego de palabras: marca la diferencia entre un sistema que confía en el juzgador porque puede revisarlo y uno que confía porque no puede. Si la motivación no es directamente una garantía epistemológica, sí lo es indirectamente, en la medida en que permite un control sobre ese irreductible espacio de discrecionalidad que es el ámbito de la libre valoración, y constituye por ello la «garantía de cierre del sistema cognoscitivista» (Gascón, 2010, p. 177).

La convicción subjetiva falla en tres frentes, pues no es medida, no puede comunicarse y no puede verificarse. La motivación resuelve los dos últimos y no resuelve el primero: obliga a comunicar y hace posible verificar, pero no dice cuánto basta. Una sentencia puede estar impecablemente motivada y aplicar, sin decirlo, un umbral distinto del que aplicó la sentencia anterior sobre el mismo tipo de hechos. Motivación y estándar son, por tanto, exigencias complementarias y no intercambiables, y confundirlas conduce al error de suponer que basta escribir más para decidir mejor (Gascón, 2010, p. 178). La primera consiste en mostrar el esfuerzo realizado por el juez en el juicio de hecho y posibilitar de ese modo un control público. La segunda facilita a los órganos de revisión un conocimiento más claro y detallado de las razones del fallo, y facilita también a la parte perjudicada su eventual impugnación, hasta el punto de que la motivación es el espejo revelador de los errores del juzgador (Gascón, 2010, pp. 178-180).

La segunda función no puede absorber a la primera. La motivación como mecanismo de garantía, en un diseño procesal de raíz constitucional, «no puede limitar su funcionalidad al ámbito de las relaciones inter partes, asumiendo necesariamente una función extraprocesal» de la que deriva la apertura de un ámbito de relaciones cuyos sujetos son, por un lado, el tribunal y, por otro, la

totalidad de los asociados, que se constituyen en destinatarios de la sentencia (Andrés Ibáñez, 1992, p. 261). La constitucionalización del deber de motivar implica que a la tradicional función endoprosesal se agregue una función extraprosesal, de modo que «la motivación representa, en efecto, la garantía de la controlabilidad del ejercicio del poder judicial fuera del contexto prosesal, y entonces por parte del *quivis de populo* y de la opinión pública en general» (Taruffo, 2013, p. 104).

«El significado profundo de las garantías está, en efecto, en la posibilidad de que el control sea puesto en práctica, no en el hecho de que sea efectuado concretamente en cada caso individual» (Taruffo, 2013, p. 104). La garantía no depende de que alguien la use, sino de que pueda usarse. La observación resulta especialmente pertinente en el contencioso electoral, donde una sentencia que resuelve sobre la validez de una elección no afecta solo a quien impugnó y a quien fue declarado electo, sino a un cuerpo electoral que no es parte y que, sin embargo, es destinatario del resultado. Si la única función reconocida a la motivación fuese facilitar el recurso, en una materia donde muchas decisiones son terminales el deber quedaría vaciado justamente allí donde más importa. La idea de la motivación como instrumento de control externo está ligada a una concepción democrática del ejercicio del poder, mientras que la imposibilidad de control sobre el fundamento de la decisión corresponde a una concepción autoritaria (Taruffo, 2013, pp. 107-108).

1.9.2. *Motivación-actividad y motivación-documento*

La exigencia de motivar no opera solamente después de decidir: opera sobre el modo de decidir. La exigencia de trasladar a terceros los verdaderos motivos de la decisión, lejos de resolverse en una simple exteriorización formal de éstos, «retroactúa sobre la propia dinámica de formación de la motivación y de la misma resolución en todos sus planos; obligando a quien la adopta a operar, ya desde el principio, con unos parámetros de racionalidad expresa y de conciencia autocrítica mucho más exigentes». «No es lo mismo resolver conforme a una corazonada, que hacerlo con criterios idóneos para ser comunicados». Quien sabe que tiene que motivar encuentra el campo de las soluciones eventuales restringido al de las opciones racionalmente justificables, y se vería constreñido a rechazar una determinada opción, quizá conforme a sus principios, cuando no fuese capaz de argumentarla favorablemente (Andrés Ibáñez, 1992, p. 291).

La conciencia de tener que motivar «condicione la formulación de la decisión sometiéndola a controles racionales y jurídicos»: la exigencia retroactúa sobre el

propio *iter* de adopción de la decisión provocando la expulsión de los elementos de convicción no susceptibles de justificación y propiciando que la decisión se adopte conforme a criterios aptos para ser comunicados, «en detrimento de la "corazonada", que resultará más difícil de justificar» (Gascón, 2010, p. 180). El juez que sepa que tiene que motivar será inducido a razonar correctamente aun cuando está evaluando las pruebas y formulando la decisión (Taruffo, 2013, p. 106). Un juzgador que sabe que deberá enunciar la máxima de experiencia empleada tenderá a escoger una máxima defendible, y uno que sabe que deberá justificar por qué descartó una prueba de descargo tenderá a examinarla antes de descartarla. La motivación no es, por ello, la última operación del razonamiento probatorio, sino una condición de todas las anteriores.

Contra esa exigencia suele oponerse que equivale a pedir un imposible, porque nadie puede reproducir por escrito el proceso mental que lo condujo a una conclusión. La motivación-actividad es «el procedimiento mental que ha conducido al juez a formular como verdadero un enunciado sobre los hechos del caso», y versa sobre el contexto de descubrimiento. La motivación-documento es «el conjunto de enunciados del discurso judicial en los que se aportan las razones que permiten aceptar otros enunciados fácticos como verdaderos», y versa sobre el contexto de justificación (Gascón, 2010, p. 184). Lo que el derecho exige es la segunda: el razonamiento justificativo que presupone la decisión y está orientado a mostrar que hay buenas razones y argumentos lógicamente correctos para considerarla válida y aceptable (Taruffo, 2013, p. 106). Pensar que la motivación es una grabación de lo que el juez pensó constituye una concepción errónea.

La distinción no autoriza el divorcio. No puede ni separarse tajantemente ambas motivaciones ni identificarlas por completo. En un modelo cognoscitivista la motivación-documento ha de coincidir con la motivación-actividad eliminando de ella los elementos no susceptibles de justificación racional (Gascón, 2010, pp. 186-187). De ahí la regla operativa: «no se motiva apelando a la "íntima convicción", pues ésta no justifica nada, sino apelando a buenas razones capaces de una comunicación intersubjetiva» (p. 186). Tampoco se motiva apelando al conocimiento privado del juzgador, porque «la motivación no puede resumirse en un "esto es así porque yo lo sé"» (p. 182), precisión que importa en materia electoral, donde la invocación de la notoriedad de ciertos hechos es frecuente y no siempre se distingue lo que es de dominio público de lo que el juzgador simplemente sabe.

Exigir motivación no convierte al órgano revisor en una nueva instancia sobre los hechos. El control sobre la motivación sólo enjuicia si las argumentaciones

esgrimidas en favor de una decisión permiten sostener ésta, de manera que si la motivación no resulta adecuada no se le abre al órgano de control la vía para valorar él mismo la prueba, sino sólo la posibilidad de poner de manifiesto el vicio de motivación (Gascón, 2010, p. 187). Controlar la motivación no es revalorar: es verificar si lo escrito sostiene lo resuelto.

1.9.3. *Compleitud y contenido exigible*

Establecido qué se controla, queda por determinar sobre qué debe recaer la justificación. La respuesta doctrinal es unánime y exigente: sobre todo. La motivación debe justificar todas las elecciones que el juez realizó para llegar a la decisión final. Si algunas elecciones quedan faltas de justificación, eso implica que el control sobre su fundamento racional no es posible (Taruffo, 2013, p. 104). El principio se despliega en la distinción entre justificación interna —la conexión lógica entre premisas y conclusión— y justificación externa —la elección de las premisas de las que la decisión se origina—. A la justificación externa de la premisa fáctica atañen las razones por las que el juzgador reconstruyó de determinada manera los hechos, lo que implica proveer argumentos racionales relativos a cómo evaluó las pruebas y a las inferencias lógicas mediante las cuales llegó a sus conclusiones (Taruffo, 2013, p. 105).

La primera exigencia concreta recae sobre la valoración de cada elemento: el juez tiene que explicar por qué consideró confiable o no a un testigo, y «debe explicar con base en qué inferencias consideró que un indicio dado lleva a una determinada conclusión relativa a un hecho de la causa» (Taruffo, 2013, p. 105). La segunda recae sobre lo descartado. El juez debe explicitar su motivación respecto de aquellas pruebas que juzgó inatendibles, en especial si eran contrarias a la reconstrucción que él mismo elaboró. Admitir que motive sólo con base en las pruebas favorables implica el riesgo del *confirmation bias*. Por eso «la evaluación negativa de las pruebas contrarias es indispensable para justificar el fundamento de la decisión» (pp. 105-106).

El deber de motivar alcanza a todas las pruebas, aunque hay exenciones fundadas. La que la práctica forense aplica con más frecuencia es precisamente la rechazable: reservar la exigencia de motivación para la prueba indiciaria y aliviarla en la llamada prueba directa. La prueba directa tiene también naturaleza inductiva, y lo único que la separa de la prueba indirecta o indiciaria es el número de pasos inferenciales de que consta. Nada la exime, por lo tanto, de la exigencia de

motivación (Gascón, 2010, p. 183). Cuando se admite la llamada motivación implícita, «la renuncia no es, como parece querer sugerirse, (solo) a la expresión de la motivación, sino a la motivación misma» (Andrés Ibáñez, 1992, p. 290).

La figura jurisprudencial de la apreciación conjunta de la prueba, cuando funciona como subterfugio, «hace pasar por discurso justificatorio lo que no lo es en absoluto; un expediente, en fin, que propicia y encubre la ausencia de motivación» (Gascón, 2010, p. 177). Lo que se denuncia es la declaración genérica de hechos probados que invoca el conjunto para no razonar ninguno de sus elementos. La agregación analítica valora primero cada elemento y determina después el grado de corroboración que el conjunto confiere a la hipótesis, obligando a justificar tanto los elementos como la relación que guardan entre sí.

Una hipótesis fáctica está justificada si no ha sido refutada y es confirmada por las pruebas disponibles más que cualquier otra. Cada elemento impone deberes precisos. Justificar que la hipótesis no ha sido refutada supone demostrar que no ha habido contrapruebas o que las eventuales contrapruebas han sido destruidas. Justificar que está confirmada requiere exponer y justificar las pruebas o indicios de los que se parte, la ley general de la que se parte, y mostrar que esos indicios constituyen una instancia particular del antecedente de esa ley. El grado de confirmación depende no sólo de la cantidad de datos favorables sino también de su variedad. Justificar que la hipótesis está más confirmada que sus rivales exige explicar las razones por las que se eligió una y se abandonó la otra, y afecta incluso a la forma de estructurar el razonamiento en la sentencia, que «debe reflejar la confrontación de las hipótesis» (Gascón, 2010, pp. 195-197).

Para que la hipótesis pueda considerarse válida se precisa una pluralidad de confirmaciones, es preciso que resista las contrapruebas y tienen que resultar desvirtuadas todas las hipótesis alternativas. Cuanto mayor es la distancia, y por tanto mayor el número de inferencias necesarias para derivar de los hechos probatorios el *thema probandi*, menor es el grado de probabilidad de la inducción probatoria. Sobre las máximas de experiencia: ordenar el razonamiento en forma justificativa obliga al juzgador a ordenar el material probatorio ya contrastado, a verificar la forma en que lo ha sido y a hacer explícitas las máximas de experiencia empleadas (Andrés Ibáñez, 1992, pp. 284-286).

La intermediación es una garantía, pero sólo de carácter instrumental. Cuando se la usa como barrera para vetar el acceso al examen del curso valorativo del tribunal, «se convierte en una injustificable coartada, primero para propiciar que el juez oculte sus razones; y, después, para negar legitimidad a cualquier tentativa de

fiscalizarlas» (Andrés Ibáñez, 1992, p. 297). La salida consiste en distinguir el juicio sobre el hecho del juicio sobre el juicio, distinción que permite admitir el control lógico sobre la adecuación de la motivación en materia de hecho, esto es, sobre la carencia de confirmaciones o sobre la presencia o no experimentación de contrapruebas.

Las inferencias pueden controlarse precisamente porque no dependen sustancialmente de la inmediación, sino de la corrección del razonamiento que se debe fundar en las reglas de la lógica, en los principios de la experiencia y, en su caso, en conocimientos científicos. El artículo 16, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral ordena valorar conforme a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia. Si esos son los patrones que la ley impone, esos mismos son los patrones respecto de los cuales la valoración puede ser revisada.

El defecto de motivación produce indefensión y encarna una forma de ejercicio arbitrario de un poder público, no sólo en el caso de motivación incorrecta, sino también en el de pura y simple falta de expresión de la motivación (Andrés Ibáñez, 1992, p. 299). A la *intime conviction* sólo puede corresponderle una falta de motivación o una motivación ficticia (Taruffo, 2013, p. 107). Las dos afirmaciones describen los dos polos de un mismo continuo. En un extremo, la sentencia que motiva mal; en el otro, la que no motiva. Y entre ambas, la que clausura el análisis antes de tener que motivar, porque declara inoperante el agravio y con ello se ahorra decir cuánta prueba habría bastado.

1.10. *Recapitulación: nueve categorías operativas*

El recorrido por las categorías de la epistemología jurídica no perseguía una exposición panorámica, sino la construcción de un instrumento. Su resultado se condensa en nueve enunciados, cada uno acompañado de la pregunta de control que genera. Ese formato responde a una exigencia interna del planteamiento: una categoría que no se traduce en una pregunta verificable no sirve para controlar nada, y sería incoherente reprochar a los tribunales la vaguedad de sus criterios empleando criterios igualmente vagos.

Las nueve categorías no son una doctrina ajena importada en bloque. Siete reproducen tesis sostenidas por los autores del corpus y una octava —la sexta— resulta de una operación de deslinde entre posiciones enfrentadas. La novena, que ordena las anteriores en forma de rejilla, es propia y de ella se responde. Ninguna de

las nueve determina el resultado de un caso; todas determinan qué debe constar en una sentencia para que el resultado pueda discutirse.

1.10.1. *Las nueve categorías*

Primera. Falibilidad controlable. La fijación judicial de los hechos es una operación de conocimiento, susceptible de acierto y de error, y por ello sujeta a garantías epistemológicas. Sostener lo contrario, desde el realismo ingenuo o desde el escepticismo, conduce por caminos opuestos al mismo corolario: un juez infalible y, por tanto, incontrolable. La racionalidad probatoria no es un rasgo definitorio de la función de juzgar sino una conquista histórica, y lo conquistado puede perderse sin que ninguna norma se derogue. *Pregunta de control:* ¿la sentencia trata su declaración de hechos como el resultado de una averiguación que pudo salir mal, o como un acto que se agota en su propia enunciación?

Segunda. Función epistémica y regla de juicio. La averiguación de la verdad es condición necesaria —aunque no suficiente— de la justicia de la decisión, y la prueba es el instrumento epistémico exclusivo dentro del proceso. Cuando el material no alcanza, el juzgador dispone de una salida legítima y nombrable: declararlo y resolver conforme a la carga de la prueba. Lo que no resulta admisible es omitir la valoración y omitir a la vez la invocación de esa regla de juicio. *Pregunta de control:* ¿la sentencia valoró el material, o cumplió las formas del rito sin ejecutar la operación de conocimiento que las justifica? Y si lo declaró insuficiente, ¿dijo conforme a qué regla resolvía entonces?

Tercera. Los tres momentos. La actividad probatoria se descompone en conformación del conjunto de elementos de juicio, valoración de esos elementos y adopción de la decisión. Los tres son lógicamente distintos y sucesivos, aunque en la práctica se presenten entrelazados, y cada uno se rige por criterios diferentes. Describir mal el conjunto es un defecto del primer momento; no relacionar los elementos lo es del segundo; concluir que no basta sin decir cuánto habría bastado lo es del tercero. Los tres suelen presentarse juntos bajo una misma fórmula de rechazo. *Pregunta de control:* ¿a qué momento pertenece cada defecto que la sentencia presenta, y se están confundiendo entre sí?

Cuarta. Estructura de la inferencia. Toda inferencia probatoria se compone de razones —los hechos probatorios—, una pretensión —la hipótesis a probar—, una garantía que explica por qué aquéllas apoyan a ésta, y un respaldo que sostiene la garantía. La operación rara vez consta de un solo paso: encadena inferencias, y

cada eslabón reproduce la misma estructura y puede fallar por su cuenta. La falta de cada elemento produce un vicio distinto, lo que permite localizar el error en lugar de descalificar el razonamiento en bloque. *Pregunta de control:* ante cada conclusión fáctica, ¿cuáles fueron las razones, cuál la garantía y cuál el respaldo, y cuántos eslabones median entre el hecho probatorio y el hecho probado?

Quinta. Criterios graduales de solidez. La solidez de la inferencia admite criterios verificables desde fuera de la sentencia, ordenados según el elemento al que se refieren: fiabilidad, suficiencia, variedad y pertinencia de los hechos probatorios; fundamento y grado de probabilidad causal de la garantía; no refutación, confirmación de las hipótesis derivadas, eliminación de las alternativas, coherencia y simplicidad de la hipótesis. La solidez es gradual en dos sentidos, porque pueden concurrir más o menos criterios y cada uno puede satisfacerse en mayor o menor medida. De esa doble gradualidad depende que la rejilla no degenera en una prueba tasada de nuevo cuño. *Pregunta de control:* ¿examinó la sentencia la fiabilidad de cada fuente antes de pronunciarse sobre su valor, y utilizó la variedad del material para cerrar explicaciones rivales o se limitó a contar elementos?

Sexta. Agregación analítica del conjunto. El conjunto probatorio aporta algo que sus elementos aislados no aportan, pero no por la vía que el holismo narrativo sugiere. Lo que el conjunto hace es cerrar vías de escape: elementos de origen distinto eliminan hipótesis alternativas que elementos homogéneos, por numerosos que sean, dejarían en pie. De ahí la fórmula que gobierna la adminiculación: valorar primero cada elemento y determinar después el grado de corroboración que el conjunto confiere a la hipótesis. La categoría se construyó deslindándola de dos usos que la desnaturalizan: la apreciación global que sustituye el examen de los elementos por la elección del relato más convincente, y la fórmula de la valoración conjunta empleada para no razonar ninguno de ellos, que Gascón (2010) describe como un expediente que propicia y encubre la ausencia de motivación (p. 177). *Pregunta de control:* ¿valoró la sentencia individualmente y en conjunto, o redujo a una sola unidad de valoración elementos de origen independiente?

Séptima. La libre convicción es un principio negativo. La libre convicción consiste en el rechazo de las pruebas legales como suficientes para determinar la decisión, y en eso se agota. Es un principio metodológico negativo, no un criterio positivo que diga cómo debe valorarse; y la sana crítica nunca fue un criterio sustantivo, sino una remisión a máximas de experiencia que siguen debiendo enunciarse. Invocar cualquiera de las dos como fundamento de una valoración

equivale a nombrar el espacio donde la justificación debía estar. *Pregunta de control:* ¿la sentencia invoca la libre convicción, la sana crítica o la experiencia como si fueran criterios, sin enunciar ninguno?

Octava. Un estándar subjetivo no es un estándar. Un estándar de prueba, para serlo, necesita tres atributos: ser una medida, poder comunicarse y poder verificarse. La convicción íntima carece de los tres. Su empleo produce, además, un efecto asimétrico, pues el mismo material puede bastar para tener por acreditada una afirmación y no bastar para la contraria, sin que exista criterio alguno para resolver el desacuerdo. El umbral debe, por ello, enunciarse antes de valorar y ser el mismo para acreditar la regularidad y la irregularidad. *Pregunta de control:* ¿enunció la sentencia el umbral que aplicó, y es ese umbral el mismo que empleó para tener por acreditados los hechos favorables a la autoridad?

Novena. Motivación completa como condición del control. La motivación es la garantía de cierre del sistema: no es una garantía epistemológica directa, pero permite controlar el espacio de discrecionalidad que la libre valoración abre. Debe abarcar todas las elecciones del juzgador, incluida la valoración negativa de las pruebas contrarias, y no admite rebaja para la llamada prueba directa. Lo que se controla no es el proceso mental del juzgador sino el documento que lo justifica, de modo que el control no autoriza a revalorar sino a verificar si lo escrito sostiene lo resuelto. Y la exigencia retroactúa: quien sabe que deberá justificar opera desde el principio con parámetros más exigentes. *Pregunta de control:* ¿justificó la sentencia lo que descartó, y permite su texto el juicio sobre el juicio, o exige al lector reconstruir por su cuenta el razonamiento que no consta?

1.10.2. Alcance y límites de la rejilla

Las nueve categorías se convierten en instrumento de análisis a través de sus preguntas de control, que admiten codificación como presente, ausente o parcial sobre cualquier resolución. Seis de ellas interrogan operaciones identificables en el texto de una sentencia: el inventario del material, la acreditación autónoma del hecho fuente, la enunciación expresa de la máxima de experiencia, el uso de los cuatro operadores del artículo 16, párrafo 3 —los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí—, la contrastación con hipótesis rivales y la enunciación del umbral aplicado. Las categorías primera, segunda y novena operan de modo transversal: la primera y la segunda determinan si hubo valoración, y la

novena, si lo que hubo quedó en condiciones de ser verificado. Son las que permiten distinguir dos situaciones que un análisis puramente cuantitativo confundiría: una valoración defectuosa, que se corrige mejorando el razonamiento, y una valoración omitida, que no se corrige en absoluto.

Cuatro limitaciones deben quedar registradas. La primera concierne al alcance de lo construido: la rejilla permite decir cuán sólida es una inferencia, no cuán sólida debe ser. Esa segunda pregunta ya no pertenece a la epistemología sino al derecho, y se resuelve en atención a los valores en juego en cada tipo de proceso.

La segunda concierne al origen del material. Las categorías provienen de una doctrina construida con la mirada puesta en el proceso penal y en el civil, y el régimen de garantías propio del primero —donde rige la presunción de inocencia y existe una asimetría deliberada entre los tipos de error— no se traslada sin más a la materia electoral. Lo que se toma es algo más básico y no dependiente de la materia: la tesis de que la fijación judicial de los hechos es una operación de conocimiento y admite, por tanto, criterios de corrección verificables. El traslado de categorías construidas sobre precedentes penales exige justificación propia allí donde llegue a invocarse.

La tercera es un riesgo que el propio instrumento genera. Un modelo de justificación no es la justificación, y confundirlos supone incurrir en la falacia de quien toma el deber ser por el ser. Cualquier rejilla de valoración corre ese peligro, porque puede degradarse hasta convertirse en una plantilla que legitime formalmente decisiones que no ejecutaron ninguna de sus operaciones. La única defensa consiste en exigir que cada una conste de manera verificable en el texto de la sentencia, y no basta con invocarla en abstracto.

La cuarta delimita el tipo de trabajo realizado. Cuanto antecede es reconstrucción conceptual y no análisis empírico. Afirma que estas nueve categorías permiten leer críticamente una sentencia; no afirma todavía nada sobre lo que las sentencias contienen. Esa comprobación exige aplicar la rejilla al corpus mediante una codificación reproducible, que determine en qué medida la valoración relacional ordenada por el artículo 16, párrafo 3, llegó a practicarse, cuándo alcanzó su mayor desarrollo y en qué momento dejó de aplicarse sin que ningún criterio fuera formalmente abandonado.